

위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점*

— 기간제근로자를 중심으로 —

강 선 희**

목 차

- | | |
|--|----------------------------|
| I. 들어가는 글 | IV. 논아웃소싱업체의 변경 등과
근로관계 |
| II. 위탁 등 아웃소싱계약기간과 근로
계약기간 | V. 나가는 글 |
| III. 위탁 등 아웃소싱계약의 중도해지·
종료와 근로관계 종료 | |

I. 들어가는 글

위탁·용역·도급 등은 통상적으로 기업 내의 업무를 위임이나 도급의 형식으로 외부업체에게 맡겨 수행하도록 하는 아웃소싱(out-sourcing, 외주화)한 사업을 칭하는 것으로 그 명칭도 외주, 사내하도급 등 다양하게 사용된다. 이 글에서의 위탁·용역·도급 등도 위와 같이 기업 내의 업무를 외부업체에게 맡겨 수행하도록 하는 아웃소싱을 칭하는 용어로 사용할 것이다. 이들의 법적 성격은 그 실질에 따라 사무의 처리를 위탁하는 위임(민법 제680조) 또는 일의 완성을 목적으로 하는 도급(민법 제664조)인 경우가 많다. 명목상 위탁·도급계약이더라도 실질적으로 근로계약인 경우가 있으나 이 글에서 다룰 영역은 수탁

DOI: <https://doi.org/10.46329/LLF.2023.03.38.139>

논문투고일자: 2023.01.20., 심사일자: 2023.03.05., 게재확정일자: 2023.03.13.

* 고려대학교 노동·일반대학원 강사, 법학박사

업체, 수급인, 용역업체, 사내하청업체, 외주업체 등이 원청(원사업주)으로 불리우는 위탁자, 도급인, 위임인 등으로부터 위탁받은 사무를 처리하거나 도급받은 일을 수행하기 위해 근로자를 고용하는 경우이므로 이는 제외한다. 이와 같은 사업은 일의 완성에 필요한 기간 또는 사무처리의 위탁기간이 정해져 있으므로 통계적으로 명확히 확인되지 않으나 이들 사업의 특성상 기간제근로자가 상당수 종사할 것으로 보인다. 2022. 8. 경제활동인구 근로형태별 부가조사에 따르면, 전체 비정규직(정규직 대비 37.5%) 8,156천명 중 위탁 등이 많을 것으로 보이는 대표적인 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업에 871천명(10.7%)으로 보건업 및 사회복지서비스업(1,388천명, 17%) 다음으로 많은 비중을 차지하고, 사회복지서비스업의 경우에도 위탁 등이 많이 행해지는 산업 중 하나이다. 2021. 전체 근로자 4,068,635명 중 55세 이상 근로자가¹⁾ 699,391명(17.2%)이고, 이들 고령자 중 239,063명(34.2%)이 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업에 가장 많이 종사하는 것에 비추어 보면 위탁 등의 사업에 고령자가 많이 분포하는 것을 알 수 있다.²⁾

위탁 등 아웃소싱과 관련하여 종전의 논의는 기업 내의 업무를 외주화(아웃소싱으로의 전환)하거나 아웃소싱업체(용역업체 등)의 변경이 영업양도(사업이전)인지, 그리고 이에 따라 그 업무를 담당하던 근로자의 근로관계가 승계되는지 여부, 원청으로 불리우는 도급인·위임인 등의 사용자성 등이 주요하게 다루어졌다. 이같은 이를 제외한 위탁·용역·도급 등의 아웃소싱사업을 둘러싼 노동법적 쟁점을 기간제 근로계약을 체결한 근로자를 중심으로 검토하고자 한다. 먼저 위탁 등의 아웃소싱계약기간과 기간제 근로계약의 관계를 시용계약과 사용기

1) 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률에 따르면 55세 이상인 사람을 고령자라 한다.

2) 고령자고용현황, KOSIS, 고용노동부. 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 근로자 총 608,040명 중 고령자가 239,063명으로 39.3%를 차지하고 있다.

간제한의 예외를 중심으로 살펴보고, 두 번째로 위탁 등의 아웃소싱 계약의 중도해지·종료와 근로관계 종료를 두 가지 판례(대법원 2009. 2. 12. 선고 2007다62840 판결과 대법원 2017. 10. 31. 선고 2017다 22315 판결)를 중심으로 검토한다. 마지막으로 아웃소싱으로의 전환 내지 아웃소싱업체의 변경 시 근로관계의 승계 법리를 고용승계기대권을 중심으로 살펴본다.

Ⅱ. 위탁 등 아웃소싱계약기간과 근로계약기간

1. 기간제 근로계약과 시용계약

(1) 근로자가 위탁업체 등에 입사할 때 사용자와 최초의 근로계약을 체결하면서 근로계약기간과 별도로 수습(시용)기간을 설정하거나 수습(시용)을 목적으로 근로계약기간을 정하는 경우가 있다. 수습과 시용은 실무에서 혼용하고 있는데, 그 법적 성격이 수습(修習)인지 시용(試用)인지 여부는 사용되는 용어가 아니라 그 실질에 따라 결정된다. 수습은 정식 근로계약 체결 후에 근로자의 근무능력이나 사업장에서의 적응능력을 향상하기 위한 제도이다. 한편 시용은 근로자를 기업조직에 확정적으로 편입시키는데 신중을 기하기 위하여 정규사원으로 임명하기 전에 일정기간을 정하여 근로자의 직업적성과 업무능력 등을 판단하려는 제도이다. 그래서 기업실무에서 용어를 수습으로 사용하더라도 그 취지로 보아 근로자의 직업적 능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 관찰·판단하고 평가하여 근로자로서의 적격성이 인정될 경우 시용기간 만료 시 본채용을 하는 것이라면³⁾ 이는 ‘시용’으로 판단해야 한다. 이와 같은 시용(試用)은 용어 그대로 근로자

3) 대법원 2022. 2. 17. 선고 2021다218083 판결 등

로서의 업무적격성 판단을 위한 시험적으로 고용하는 것으로⁴⁾ 그 성격상 본채용은 일반적으로 정규직(기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자, 무기계약근로자)을 의미하는 경우가 통상적일 것이다. 그러나 실제 근로계약기간을 1년 내지 6개월로 정하면서 최초의 3개월은 시용으로 한다거나(①유형), 근로계약기간과 시용기간을 3개월로 동일하게 정하거나(②유형), 근로계약기간에 3개월로 명시하면서 시용을 목적으로 한다고 정하는 경우(③유형)가 있다. 이러한 경우 통상의 기간제 근로계약을 체결한 것으로 보아 기간제 관련 법리를 적용할 것인지 아니면 이와 구별되거나 특수한 시용의 법리를 적용할 것인지, 유형별로 달리 판단할 것인지가 문제 시 될 수 있고, 시용근로자의 법적 지위가 무엇인지에 따라 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 ‘기간제법’이라 한다)의 적용 여부도 결정된다.

(2) 구체적인 논의의 전개를 위해 시용근로자의 법적 지위를 먼저 살펴본다.

시용기간의 법적 성격에 대해 판례는 ‘시용기간 중에 있는 근로자를 해고하거나 시용기간 만료 시 본계약의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사’로서 근로자로서의 업무적격성이 부족하다는 객관적인 합리적 이유가 있어야 한다고 하고⁵⁾, 학계도⁶⁾ 이

4) 대법원 2022. 2. 17. 선고 2021다218083 판결, 대법원 2022. 4. 14. 선고 2019두55859 판결. “시용이란 본 근로계약 체결 이전에 해당 근로자의 직업적 능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 관찰·판단하고 평가하기 위해 일정기간 시험적으로 고용하는 것을 말한다.”

5) 대법원 1992. 8. 18. 선고 92다15710 판결, 대법원 1994. 1. 11. 선고 92다44695 판결, 대법원 2005. 7. 15. 선고 2003다50580 판결, 대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결 등

6) 김형배, 「새로 쓴 노동법」 제25판, 박영사, 2016, 283면(한편 기간의 정함이 없는 근로관계와 연결되지 않는 별개의 독립된 시용기간으로 해석되는 특별계약설이라고 한다, 286면). 임종률, 「노동법」 제20판, 박영사, 2022, 413면(해약권이 유보된 특수한 근로계약).

와 같은 판례의 입장(해약권유보부 근로계약설)을 지지하고 있다. 이러한 법적 성격은 시용기간 중의 해고 또는 본채용의 거부 시 근로기준법 제23조 제1항의 ‘정당한 이유’에 대한 심사의 정도 내지 심사기준과 관련된 것으로 본채용 거절 등은 사용자에게 유보된 해약권의 행사이고, 시용제도의 취지 및 목적에 비추어 통상의 해고(정규직에 대한 해고)보다 완화된 기준을 적용한다는 것을 의미한다.⁷⁾ 한편 우리나라에서는 주장되지 않았으나 일본에서 한때 논의되었던 정지조건부·해제조건부 근로계약이 있다. 이에 대한 개별적인 학설 다툼은 별론으로 하더라도, 실무적으로 보면 근로자로서의 적격하다는 평가를 정지조건으로 본채용이 이루어지는 정지조건부 근로계약이든 근로자로서의 부적격하다는 평가를 해제조건으로 보아 근로계약이 해지되는 해제조건부 근로계약이든 조건(근로자로서의 업무적격성)의 성취 여부가 본채용의 조건이 된다는 측면에서 차이가 없다. 또한 조건의 불성취로 인한 법률효과(본채용 거부)는 당연히 발생하는 것이 아니라 사용자가 해지권을 행사하여야 하며, 이와 같은 사용자의 해지권 행사는 해고제한법리가 적용된다는 측면에서 별반 차이가 없다고 볼 수도 있다. 또한 일부 판례도⁸⁾ 시용계약을 조건부 계약(‘시용조건부 근로계약’)으로 표현하기도 하였다. 그러나 ‘조건’ 등의 부관(附款)은 법률행위의 성립을 전제로 그 효력 발생 또는 소멸에 관한 것이므로, 조건부 계약은 계약의 성립을 전제로 그 계약의 효력 발생 또는 소멸을 조건의 성취 여부에 의존케 하는 계약이다. 이러한 측면에서 보면 시용근로계약은 조건부 계약으로 보기 어렵다. 이와 같은 내용을 종합

7) 대법원 2022. 2. 17. 선고 2021다218083 판결, 대법원 2022. 4. 14. 선고 2019두55859 판결 등(“시용기간 중에 있는 근로자를 해고하거나 시용기간 만료 시 본계약의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서, 당해 근로자의 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 관찰·판단하려는 시용제도의 취지·목적에 비추어 볼 때 보통의 해고보다는 넓게 인정되나, 이 경우에도 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여 사회통념상 상당하다고 인정되어야 할 것이다.”)

8) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결(이의 원심인 서울고등법원 2002. 10. 9. 선고 2000나49130 판결)

하면 통설과 판례의 견해와 같이 시용계약은 사용자가 근로자를 정식 사원으로 채용하는 것이 적절하지 않다고 평가할 경우 향후 근로계약을 해지하기로 하면서 체결한 해약권유보부 근로계약으로 봄이 타당하다. 그런데 이러한 해약권유보부 근로계약설은 본채용 거부의 성질을 설명할 뿐 시용근로자의 법적 지위를 설명하는 데에는 다소 미흡한 측면이 있다.

시용계약은 본채용을 전제로 시용(試用, 시험적 고용)을 목적으로 기간을 정하여 체결한 근로계약이므로 고용형태로 분류하면 기간제 근로계약의 특수한 유형이고⁹⁾, 시용근로자의 법적 지위는 기간제근로자로 볼 수 있다. 이러한 연유로 시용근로자에 대해서도 기간제법상 사용기간의 제한(기간제법 제4조) 및 차별금지규정(기간제법 제8조) 등이 적용된다.¹⁰⁾ 기간제법 제4조 제1항[“사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 기간제 근로자를 사용할 수 있다.”]의 사용기간 2년 산정 시 시용기간을 포함하여 2년을 초과하는지 여부를 판단한다.¹¹⁾ 또한 시용기간 중 시용의 목적을 벗어나 합리적인 이유 없이 정규직에 비해 불리한 처우를 하였다면 기간제법 제8조에 따라 사용자의 차별적 처우로부터 구제받을 수 있는 당사자적격이 인정된다.¹²⁾

한편 통상의 기간제 근로계약은 갱신기대권 등이 인정되는 특별한

9) 근로관계의 존속기간인 근로계약기간을 정한 통상적인 기간제 근로계약과는 차이가 있다.

10) 강선희, “채용형 인턴 및 정규직 전환자의 법적 지위와 차별행위로 인한 손해배상-대구지방법원 2022. 6. 16. 선고 2020가합212341 판결 -”, 월간 「노동리뷰」 2022년 8월호(통권 제209호), 한국노동연구원, 2022, 110~114면 참조

11) 대법원 2018. 1. 25. 선고 2017두59987 판결. 이 판결은 시용기간을 포함하여 기간제근로자로서 계속근로한 총기간이 2년을 초과하여 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로자로 전환되었다고 판단하였다.

12) 대구지방법원 2022. 6. 16. 선고 2020가합212341 판결. 이에 대한 평석은 각주 10) 참조

사정이 없다면 근로자와 사용자가 정한 근로계약기간이 끝나면 근로관계는 사용자의 해고 등의 별도의 조치를 기다릴 것 없이 당연히 종료하는 것이 원칙이나, 갱신기대권이 인정되는 경우 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 ‘부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없’으므로¹³⁾ 근로기준법상 해고제한 법리(근로기준법 제23조 제1항과 제28조)가 적용된다.¹⁴⁾ 시용계약은 이와 달리 시용기간 만료 시 본계약(本契約)의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 해고에 해당하고, 해고가 정당하기 위해서는 근로자로서의 업무적격성이 부족하다는 객관적인 합리적 이유가 있어야 한다.¹⁵⁾ 이 양자에게 해고제한법리가 적용되나 통상의 기간제 근로계약은 근로계약기간이 만료되면 근로관계가 당연히 종료하는 것을 원칙으로, 예외적으로 갱신기대권(정규직 전환기대권 등을 포함)이 인정될 경우 갱신 거절의 합리적 이유의 유무에 따라 부당해고와 마찬가지로의 효과 내지 기간 만료의 효과가 발생한다. 반면 시용계약은 본채용을 전제로 시용기간(시험적 고용기간)을 설정한 것이므로 시용기간이 만료되면 근로관계가 당연히 종료하는 것이 아니라 본채용을 하는 것이 원칙이므로 본채용 거부는 ‘해고’이고, 본채용 거부하는 근로자로서의 업무적격성이 부족하다는 요건을 충족할 경우에만 정당화된다. 이러한 측면에서 시용기간 만료 후 당사자 간에 시용기간을 연장하는 등의 별다른 약정이 없거나 유보된 해지권을 행사하지 않는 한 본채용이 된 것으로 간주되나, 기간제 근로계약의 경우 근로계약기간의 만료 후 사용자가 기간 만료를 통보하지 않더라도 당연히 계약이 갱신되는 것은 아니다. 이상의 내용을 정리하면 기간제 근로

13) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등

14) 강선희, “해고의 서면 통지 요건과 갱신 거절 등-대법원 2021. 10. 28 선고 2021두45114 판결-”, 월간 「노동리뷰」 2022년 1월호(통권 제202호), 한국노동연구원, 133~137면 참조

15) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결 등

계약의 기간 만료는 해고가 아니나 갱신기대권 등이 인정되고 갱신 거절의 합리적 이유가 없는 경우에 한정하여 ‘해고와 마찬가지로의 효과’가 부여되는 한편, 시용계약에서 본채용 거부하는 ‘해고’이고, 근로자로서의 업무적격성이 부족할 경우에 한정하여 그 해고가 정당화된다. 이러한 이유로 시용계약은 통상의 기간제 근로계약과 달리 근로기준법상의 해고제한규정, 즉 근로기준법 제23조 제2항의 해고금지시기, 제26조의 해고의 예고, 제27조 해고사유 등의 서면통지 규정이 적용된다. 근로기준법은 제23조 제2항에 사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다고 규정하여 해고를 제한하고 있는데 이는 근로자가 업무상의 재해로 인하여 노동력을 상실하고 있는 기간과 노동력을 회복하는데에 필요한 그 후의 30일간은 근로자를 실직의 위협으로부터 절대적으로 보호하기 위한 것이므로 시용근로자에 대하여도 동일하게 적용되고, 시용근로관계에 있는 근로자가 위 해고금지시기에 있다면 사용자는 시용근로자를 해고하거나 본계약 체결을 거부하지 못한다고 봄이 타당하다.¹⁶⁾ 시용근로자에 대한 해고예고의 경우에도 현행 근로기준법 제26조 단서 제1호에¹⁷⁾ 따라 “근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우”를 제외하고 계속 근로한 기간이 3개월 이상이면 해고예고를 해야 한다. 실무상 시용기간을 3개월로 정하는 경우가 많은데, 예컨대 시용기간을 2023. 3. 1.~2023. 5. 31.로 정하고 종료일인 2023. 5. 31.까지 근무하였다면 계속 근로한 기간이 3개월 이상이므로 해고예고를 해야 한다.¹⁸⁾ 또한 시용은 시용기간 만료 시 본계약(本契約)의 체결을 거부하는 것은 해고이므로 근로기준법 제27조에 따라

16) 대법원 2021. 4. 29. 선고 2018두43958 판결

17) 해고예고의 적용 예외를 규정한 구 근로기준법 제35조가 헌법재판소에서 2015. 12. 23. 단순위헌(2014헌바3)으로 결정되어 2019. 1. 15. 법률 제16270호로 삭제되고 제26조를 현행과 같이 개정하였다.

18) 근로기준정책과-1330, 2021. 5. 4., 법제처 21-0320, 2021. 9. 8.

해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.¹⁹⁾²⁰⁾

(3) 다음으로 위에서 언급한 유형①~③에 대해 검토하기에 앞서 실제 사례를 보도록 한다. 예컨대 근로계약서의 상단에 ‘근로계약기간’은 “2015. 12. 1.부터 2016. 2. 29.까지(3개월)로 기한의 정함이 있는 것으로 하며, 계약기간 종료 또는 계약기간 중이라도 피고와 사업장 사이의 위·수탁(도급)계약이 해지(종료)되는 경우 근로계약은 자동종료 되는 것”으로, 하단에 ‘기타 조건’으로 “입사 후 최초 3개월의 수습기간을 거쳐 정식 직원으로 임명되며 이와 관련한 사항은 취업규칙에 따르는 것”으로 정한 경우이다.²¹⁾ 위 근로계약서에서도 ‘수습기간’이란 용어를 사용하였으나 취업규칙과의 관계에서 파악하면 이는 정식 직원 채용 전의 시용기간을 의미하는 것으로 보이고, 위의 ②유형에 해당한다. 이 사안에서 근로자는 자신의 근로계약이 시용계약이므로 사용자가 해고의 서면통지 절차를 위반하였다고 주장하는 반면, 사용자는 기간제 근로계약이므로 해고의 서면통지 절차를 준수할 필요가 없다고 주장하였다. 원심은²²⁾ 위 근로계약서 ‘기타 조건’의 ‘수습기간’은 시용기간을 의미하는 것으로 보았고, 공동주택의 사업주체나 입주자대표회의 등과의 단기 계약을 통해 한시적 위탁관리 업무를 하는

19) 대법원 2015. 11. 27. 선고 2015두48136 판결(위와 같은 근로기준법 규정의 내용과 취지, 시용기간 만료 시 본 근로계약 체결 거부의 정당성 요건 등을 종합하여 보면, 시용근로관계에서 사용자가 본 근로계약 체결을 거부하는 경우에는 해당 근로자로 하여금 그 거부사유를 파악하여 대처할 수 있도록 구체적·실질적인 거부사유를 서면으로 통지하여야 한다고 봄이 타당하다.)

20) 앞서 조건부 계약으로 보기 어렵다고 하였으나 설명 시용계약을 해제조건부(解除條件附) 계약으로 보더라도 달리 판단되지 않는다. 해제조건(解除條件) 즉 근로자로서 부적격성이 인정된다면 근로계약이 해제되므로 그 해제조건 달성 여부는 해고의 정당성을 판단하는 사유이므로 그 사유를 근로자에게 서면으로 통지해야 한다.

21) 피고의 취업규칙은 시용기간(제4조)에 대해 “직원을 정식 채용하기 전에 직접 적성·업무능력과 회사에의 적응성을 판단하기 위하여 시용기간을 설정할 수 있으며, 시용기간 만료 시 직원으로의 적격성 여부를 판단하여 정식 채용 여부를 결정한다.”라고 정하고 있다.

22) 서울고등법원 2017. 5. 26. 선고 2016나210391 판결

위탁업체(사용자)의 업무의 특성상 소속 근로자에 대해 단기간으로 하는 근로계약이 필요하여 위 근로계약기간에도 그와 같은 점이 반영된 것으로 보이지만 시용기간을 규정한 것임이 명백한 ‘기타 조건’을 부정하거나 무시할 수 없는 등의 사정에 비추어 위 근로계약은 시용계약으로 보아야 한다고 판단하였다. 대법원도²³⁾ 별다른 설시 내용 없이 원심 판단을 수긍하였다.

위와 같은 판결 내용을 종합하면 통상의 기간제 근로계약과 시용계약이 중첩적으로 나타날 경우, 위 유형②와 ③과 같이 근로계약기간으로서의 성격과 시용기간으로서의 성격이 동시에 나타날 경우에는 시용계약으로 보아야 한다.²⁴⁾ 시용계약은 본채용을 전제로 시험적 고용을 목적으로 기간을 정한 계약, 즉 시용을 목적으로 계약기간을 정한 특수한 기간제 근로계약으로 볼 수 있기 때문에 통상의 기간제 근로계약과 차이가 있다. 유형①의 경우는 계약서의 문언 그대로 최초 3개월은 시용기간으로, 이를 초과하는 부분은 시용기간의 만료 후의 본채용의 계약기간이다. 그리고 유형②와 ③의 시용기간 만료 후 본채용되는 경우 근로계약기간을 정하는 등의 별도의 약정이 없다면 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 보아야 한다.

2. 기간제법상 사용기간 제한의 예외

- (1) 위탁기간 등 아웃소싱기간이 사업의 완료 또는 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우인지

1) 개요

기간제법 제4조 제1항은 단서의 예외에 해당하는 경우를 제외하고

23) 대법원 2017. 10. 31. 선고 2017다22315 판결

24) 노동위원회에 실무에서 위와 같이 중첩적으로 나타나는 경우 시용을 목적으로 한 통상의 기간제 근로계약으로 판단하는 사례들이 많다.

“사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 기간제근로자를 사용할 수 있다.”라고, 같은 조 제2항은 “사용자가 제1항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.”라고 정하였다. 위탁사업 등에 종사하는 기간제근로자의 경우에도 2년을 초과하여 계속근로하면 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자(이하 ‘무기계약근로자’라 한다)로 전환되나, 예외에 해당하는 경우에는 그러하지 않다. 기간제법은 비정규직 근로자의 급격한 증가에 따른 사용자의 남용행위를 규제하기 위하여 제정되었고²⁵⁾, 이를 위해 원칙적으로 상시적인 업무의 경우 2년의 사용기간을 제한하면서도 예외적으로 허용하는 입법취지는 기간제근로자의 사용 목적상 특정기간으로 사용을 제한하는 것이 불필요하거나 적절하지 않고, 사용기간을 제한하는 방식으로의 보호가 해당 기간제근로자에게 적절하지 않거나 고소득자와 같이 사용기간을 제한하지 않더라도 근로자의 지위가 열악해질 가능성이 상대적으로 낮아 사용기간 제한을 통해 보호할 필요성이 크지 않기 때문이다.²⁶⁾ 사용기간 제한의 예외사유에 해당하는 경우 기간제법 제4조 제2항이 적용되지 않으므로 기간제법 제4조 제1항 단서의 예외사유는 예시가 아니라 제한적 열거규정으로 보아야 하고, 기간제근로자의 고용불안 해소 및 근로조건 개선이라는 입법취지에 비추어 엄격하게 해석하여야 한다.

위탁기간 등 아웃소싱기간 등이 ‘사업의 완료 또는 특정한 업무의

25) 제정이유, 국가법령정보센터

26) 서울고등법원 2013. 8. 18. 선고 2011누9821 판결에서 사용기간 제한의 예외규정을 둔 입법취지를 “기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 근로자 지위의 안정화라는 목표와 사용자가 경기 변동에 따라 고용량을 조절할 수 있는 노동시장의 유연성 제고라는 목표를 조화롭게 추구하기 위함”이라고 밝히고 있으나 이는 사용기간 제한을 2년으로 설정한 입법취지로 보인다.

완성에 필요한 기간을 정한 경우’(기간제법 제4조 제1항 단서 제1호)에 해당하는지가 주로 문제시되며, 앞서 보았듯이 고령자(기간제법 제4조 제1항 단서 제4호)가 많이 분포하고 있는 특성으로 인한 문제가 있는데 이는 별도의 향으로 나누어 서술한다.

2) 판단기준

(가) 기간제법 제4조 제1항 단서 제1호의 ‘사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우’란 건설공사, 특정 프로그램 개발 또는 프로젝트 완수를 위한 사업 등과 같이 객관적으로 일정 기간 후 종료될 것이 명백한 사업 또는 특정한 업무에 관하여 그 사업 또는 업무가 종료될 것으로 예상되는 시점까지로 계약기간을 정한 경우를 말한다.²⁷⁾ 이는 기간제법 제4조 제1항 단서 제2호(휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우) 및 제3호(근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우)와 더불어 ‘업무 자체가 한시적으로만 존속하는 경우’이다.²⁸⁾

위탁 등 아웃소싱의 대상이 된 업무 자체만을 떼어놓고 보면 ‘한시성’이란 개념 표지에는 부합하지 않는 측면이 있는데, 국가 및 지방자치단체 등이 폐기물 처리, 청소, 환경, 조경 등의 업무를 위탁하는 경우를 예를 들면 위탁의 대상이 된 업무 즉 폐기물 처리, 청소, 환경, 조경 등의 업무는 사업주체(국가 및 지방자치단체 등)에게 ‘상시적인 업무’이다.²⁹⁾ 이와 같이 위탁의 대상이 된 업무 자체가 상시적인

27) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016다255910 판결

28) 헌재 2013. 10. 24. 2010헌마219, 265

29) 사업주체가 이들 업무를 위탁업체에게 위탁하더라도 사업주체는 여전히 변동 없고, 해당 업무만이 외부 위탁업체가 처리하는 것이다. 사업주체의 변동이 없다는 측면에서 고용승계의 효과를 가져오는 사업이전(영업양도)으로 평가하지 않는 것이다. 자세한 내용은 후술한다.

업무일지라도 사업주체로부터 위탁받은 수탁업체의 입장에서는 위탁 계약기간에 한정되어 그 업무를 처리해야 하므로 한시적이라고 할 수 있다. 따라서 수탁업체 등이 사업주체로부터 위탁받은 사업 내지 업무가 한시적인지에 대한 판단기준은 ‘사업 내지 해당 업무’ 자체의 상시성·계속성 등과 상관없이 ‘위탁받은 사용자’를 기준으로 ‘사업 내지 해당 업무’가 한시적인지 여부이다. 즉 건설공사, 특정 프로그램 개발 또는 프로젝트 완수를 위한 사업 등과 같이 사업 또는 업무에 내재된 객관적 성질상 종기(終期)가 명백한 사업이나 업무만을 의미하는 것은 아니다. 또한 ‘특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우’를 해당 업무가 종료될 것으로 예상되는 시점까지로 계약기간을 정하는 것이 ‘그 업무의 객관적 성질상 반드시 필요한 경우’만을 의미하는 것도 아니다.³⁰⁾

예컨대 지방자치단체로부터 하수처리를 위탁받아 하수처리장을 운영하는 경우 해당 사업인 ‘하수처리’는 상시업무이고 종료될 것이 예견되는 한시적 사업은 아니나 위탁받은 사용자의 입장에서는 위탁기간에만 한시적으로 운영되는 것이고, 재위탁 여부가 불분명하여 사업의 지속을 예측하기 어렵기 때문에 ‘사업의 완료 등에 필요한 기간을 정한 경우’로 볼 수밖에 없다.³¹⁾ 아파트입주자대표회의(사업주체)가 시설관리업무를 위탁하는 경우도 마찬가지인데, 시설관리업무 자체는 상시적이고 계속적 업무이나 수탁업체의 입장에서는 아파트입주자대표회의로부터 그 시설관리업무를 위탁기간에 한정하여 위탁받은 경우로 해당 아파트입주자대표회의로부터 재위탁 여부가 확실하지 않아 해당 위탁사무를 처리하기 위하여 근로자를 정규직으로 고용하기 어

30) 대전고등법원 2021. 6. 10. 선고 2021나10041 판결(대법원 2021. 9. 30. 자 2021다248435 판결에서 심리불속행 기각으로 확정), 서울고등법원 2022. 1. 14. 선고 2021나2015367 판결(대법원 2022. 5. 12. 자 2022다210963 판결에서 심리불속행 기각으로 확정)

31) 서울행정법원 2021. 7. 8. 선고 2020구합73549 판결 등

려운 것이다.³²⁾ 그리고 한시성을 판단함에 있어 위탁 등의 종료가 수탁업체의 주관적 사정에 전적으로 의존하게 되는 경우가 아니라 위탁계약서에 명시된 사업완료일에 위탁업무도 종료될 것이 명백해야 한다. 즉 위탁의 계속 여부(갱신하거나 신규입찰을 통한 재위탁 여부)가 수탁업체의 주관적 사정이 아니라 사업주체의 결정에 따라야 한다. 설령 수탁업체가 공개입찰 과정을 통해 그 위탁업무를 다시 위탁받을 가능성이 있더라도 이는 불확정적인 반면 위탁계약기간의 만기가 도래하면 객관적으로 그 업무가 종료될 것이 명백한 사업에 해당해야 한다.

그러나 공공기관으로서 정부 및 지방자치단체로부터의 위탁사업을 처리할 목적으로 설립된 경우 예를 들면 A시가 운영 및 주관하는 주민체육시설, 문화센터 등을 위탁 운영할 목적으로 설립된 공공기관인 A시개발공사에서 주민체육시설 등의 운영업무는 위에 해당한다고 보기 어렵다. A시개발공사의 입장에 서더라도 한시성의 요건을 충족하지 못하기 때문이다.

한시성이라는 요건을 갖추기 위해서는 사업 완료 등에 필요한 기간이 특정되어야 한다. 즉 위탁계약기간 등이 그 사업 또는 업무의 객관적인 성격으로 인하여 일정 기간 후 종료될 것이 명백하여 기간을 따로 특정하지 않고 ‘사업 또는 특정한 업무가 끝날 때’까지로 정해져 있거나 사업 또는 업무가 끝날 것으로 예상되는 특정 시점까지로 정해져 있는 것을 말한다. 이 경우 사업 또는 특정한 업무의 종료 시점이 어느 정도 특정될 수 있고 또한 전혀 불확정인 것이 아닌 한 어느 정도 부정기적이더라도 무방하다. 또한 위탁사업이 방대하고 위탁기간도 장기어서 사업의 종기(終期)가 변경될 가능성이 크더라도 사

32) 그렇다고 정규직으로 고용하는 것이 불가능한 것은 아니다. 사적자치의 원칙에 따라 당사자 간에 무기근로계약을 체결할 수 있고, 사용자와 근로자 간 무기근로계약을 체결하였다면 해당 위탁기간이 종료되더라도 근로관계가 종료되는 것이 아니라 사용자는 근로자를 다른 사업장으로 전환배치하여야 한다.

업의 성질상 일정 기간 후에 종료될 사업이라는 사실이 명백하다면 ‘사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우’에 해당한다.³³⁾

(나) 두 번째 기준은 근로자가 위탁업무 내지 사업 등에 사용되는지 여부이다. 기간제근로자가 해당 위탁업무 내지 사업에 특정되어 사용되는 경우로 위탁업무 내지 사업이 종료될 경우 근로계약을 계속하여 유지할 수 없는 경우를 말한다. 그러나 근로자가 위탁업무 등에 사용될 것을 전제로 기간을 정하여 채용되었으나 실제 그 위탁업무 등에 사용되지 않았다면 사용기간 제한의 예외자가 아니라고 보아야 한다.

(다) 또한 사용자가 기간제법 제4조 제2항의 적용을 회피하기 위하여 형식적으로 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 근로계약을 반복갱신하여 체결하고, 각 근로관계의 계속성을 인정할 수 있는 경우에는 사용기간 제한의 예외에 해당한다고 할 수 없다. 예컨대 사용자가 수주한 건설공사의 특정 감리용역 업무를 수행하기 위해 근로자와 1년 단위로 근로계약을 체결하여 반복하였으나 특정 감리용역이 종료된 이후에도 사용자가 수주한 다른 건설공사의 감리용역 등을 수행하기 위해 근로계약을 계속 유지하면서 10여 년을 근무한 사례에서 대법원은³⁴⁾ 다수의 감리용역을 수주받아 상시적으로 감리용역 업무를 수행해야 하는 사용자의 입장에서 특정 용역현장에서의 사업이 완료되더라도 감리 업무를 수행할 수 있는 근로자와의 근로계약을 계속 유지하여야 할 필요가 있었던 것으로 보이는 점을 고려하여 ‘형식적으로 사업의 완료 등에 필요한 기간을 정한 근로계약을 반복·갱신하는 경우’라고 보았다.³⁵⁾

33) 서울고등법원 2021. 9. 1. 선고 2020누64554 판결(서울행정법원 2020. 10. 29. 선고 2020구합54913 판결을 인용·수정함)은 대법원 2022. 1. 27. 자 2021두52556 판결에서 심리불속행 기각으로 확정되었다.

34) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016다255910 판결

(라) 위 대법원 2016다255910 판결에서 기간제법 제4조 제1항 단서 제1호의 의미를 객관적으로 일정 기간 후 종료될 것이 명백한 사업에 관하여 그 사업이 종료될 것으로 예상되는 시점까지로 ‘계약기간을 정한 경우’를 말한다고 판시하여 근로계약기간 자체가 사업의 완료에 필요한 기간으로 정해야 하는 것으로 이해할 수도 있다. 그러나 반드시 사업의 완료 등에 필요한 기간과 근로계약기간이 일치해야 할 필요는 없다. 구 근로기준법 제16조는 “근로계약은 기간을 정하지 아니한 것과 일정한 사업의 완료에 필요한 기간을 정한 것 외에는 그 기간은 1년을 초과하지 못한다.”라고 규정함으로써 근로계약기간 자체가 일정한 사업의 완료에 필요한 기간을 정한 경우에는 1년을 초과할 수 있는 예외로 설정한 것이므로 결국 근로계약기간과 사업의 완료에 필요한 기간이 일치해야 한다. 그러나 기간제법 제4조 제1항 단서 제1호는 사용자가 수행하는 사업 내지 업무 자체의 한시성에 있으므로 해당 사업 내지 특정한 업무가 완성될 때까지 기간제근로자를 2년을 초과하여 사용할 수 있는 예외를 허용하는 것이고, 사전에 근로계약으로 정한 기간이 있음에도 실제로 사업이 완료되거나 특정한 업무가 완성될 때까지 계속하여 고용을 보장해야 하는 것은 아니다.³⁵⁾ 따라서 기간제법 제4조 제1항 단서 제1호에 해당하는지에 대한 판단은 해당 사용자의 사업 내지 업무 자체를 기준으로 그것이 한시적으로만 존속하면 되고, 그 기간 내에 기간제근로자를 자유로이 사용할 수 있다고 해석된다. 입법구조상 구 근로기준법은 ‘근로계약’을 기준으로 규정되어 있으나 위 기간제법 단서는 ‘사용자’를 중심으로 기간제근로자의 사용 목적에 포커스가 있기 때문이다. 또한 기간제법은 기간제

35) 이 사안에서 대법원이 사용자가 기간제법 제4조 제2항의 적용을 회피하기 위하여 형식적으로 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정하였다고 판단한 논거 중 하나가 약 10년 3개월의 재직기간 중 2005. 7. 7.부터 2012. 7. 6.까지 실제로 근로자가 근무하여야 할 감리용역현장의 근무기간이 아닌 1년 단위로 계약기간을 정하여 반복갱신하였다는 측면이다.

36) 서울고등법원 2013. 6. 20. 선고 2012누34497 판결

근로자를 사용하는 사유제한 방식에 따른 규율이 아니라 사용기간제한 방식이기 때문이기도 하다. 사용기간을 제한하는 기간제법의 입법 목적은 상시업무에 상시고용을 원칙으로 하되 한시업무에는 기간제근로자를 사용할 수 있도록 허용한 것이므로 사업 내지 업무 자체가 한시적으로만 존속하는 것으로 족하다. 다만, 정황에 따라 사업의 완료 등에 필요한 기간까지 갱신기대권이 인정될 수 있을 것이다.

(2) 고령자

기간제법 제4조 제1항 단서 제4호는 고령자고용촉진법³⁷⁾ 제2조 제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우를 사용기간제한의 예외로 정하고 있는데, 고령자는 55세 이상인 사람(같은 법 시행령 제2조 제1항)이다. 앞서 보았듯이 위탁 등이 많을 것으로 보이는 대표적인 사업 시설관리·사업지원 및 임대서비스업에 전체 고령근로자의 34.2%가 분포하는 것을 알 수 있듯이 이들 산업이 기간제법 제4조 제1항 단서 제1호에 해당하지 않더라도 이에 해당할 수 있어 사용기간의 제한을 받지 않을 가능성이 다른 영역에 비해 높다고 볼 수 있다.

사용자가 기간제근로자를 채용할 당시에 이미 55세 이상의 고령자라면 사용기간의 제한을 받지 않겠지만 채용 당시에는 55세 미만이었으나 근로하던 중 갱신할 시점에 55세 이상인 경우는 달리 판단하여야 한다. 대법원은³⁸⁾ “사용자가 기간제 근로계약을 최초로 체결할 당시 근로자가 만55세 이상인 경우 또는 기간제 근로계약을 갱신할 당시 근로자가 만55세 이상이고 기존 근로기간이 2년 이하인 경우에 비로소 기간제법 제4조 제1항 제4호 단서에 해당되어 기간제법 제4조 제2항에 따른 무기근로자로의 전환이 배제되는 것으로 해석하는 것이 기간제법

37) 고령자고용촉진법은 2008년 일부개정을 거쳐 2009. 3. 22. ‘고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률’로 법률명을 변경하였으나, 현행 기간제법에서 규정하는 명칭 및 약어로써 이하 ‘고령자고용촉진법’이라 하였다.

38) 대법원 2013. 5. 23. 선고 2012두18967 판결

제4조 제1항 제4호의 문언에 부합할 뿐 아니라 기간제근로자의 보호라는 기간제법의 입법목적에도 합치된다.”라고 판단한 원심(서울고등법원 2012. 7. 18. 선고 2011누45056 판결)³⁹⁾ 별다른 설시 내용 없이 수긍하였다. 이를 정리하면 <(i) 기간제 근로계약을 최초로 체결할 당시 근로자가 55세 이상인 경우, (ii) 기간제 근로계약을 갱신할 당시 근로자가 55세 이상이고(and) 기존 근로기간이 2년 이하인 경우>를 제외하고 사용기간의 제한이 적용되어 계속근로한 기간이 2년이 넘는 때에 무기계약자로 간주된다. 예컨대 2018. 10. 1. 최초로 근로계약을 체결할 당시 55세 미만이었고, 2019. 1. 2. 근로계약을 갱신하면서 2019. 1. 1.부터 2021. 2. 28.까지로 기간을 정하였으며, 근로자는 두 번째 근로계약 기간 중인 2020. 3. 10. 55세에 도달하였다. 사용자는 근로자에게 2021. 2. 28. 기간 만료를 통보하였는데 이는 위 요건 어느 하나에도 해당하지 않아 무기계약자로 전환되었으므로 사용자가 근로계약기간 만료를 이유로 근로관계를 종료한 것은 부당해고이다.

Ⅲ. 위탁 등 아웃소싱계약의 중도해지·종료와 근로관계 종료

1. 근로관계의 자동소멸사유

위탁계약 등의 중도해지 및 종료가 근로관계의 자동종료(소멸)사유인지에 대해 논란이 있던 중 용역계약이 해지될 때에 근로관계도 해지된 것으로 본다고 약정하였더라도 그와 같은 해지사유를 근로관계의 자동소멸사유라고 할 수 없다는 2009년 대법원 판결이⁴⁰⁾ 나온 이

39) 1심(서울행정법원 2011. 12. 2. 선고 2011구합30694 판결)을 그대로 인용하는 판결을 하였다.

40) 대법원 2009. 2. 12. 선고 2007다62840 판결

래로 실무적으로 크게 원용되지 않다가 2017년 이를 다시 확인하는 판결이⁴¹⁾ 나오면서 그간의 논란을 일단락지었다.

종래에 법원은 “근로계약기간을 정한 경우에 있어서 근로계약 당사자 사이의 근로관계는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 만료함에 따라 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 당연히 종료된다.”라고 하여⁴²⁾ 근로계약기간의 만료, 정년 및 근로자의 사망 등을 근로관계의 자동소멸사유로⁴³⁾ 보았다. 이와 같은 근로계약기간 만료 내지 정년 등 근로관계의 자동소멸사유로 인한 퇴직처리는 “법률상 당연히 발생한 퇴직의 사유 및 시기를 공적으로 확인하여 알려주는 ‘관념의 통지’에 불과할 뿐 근로자의 신분을 상실시키는 ‘해고처분’과 같은 새로운 형성적 행위가 아니다.”라고 판결함으로써⁴⁴⁾ 근로기준법상의 해고제한 법리를 적용하지 않았다. 그러던 중 갱신기대권 법리가⁴⁵⁾ 발전하면서 갱신기대권이 인정될 경우 ‘부당하게’ 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 ‘부당해고와 마찬가지로’ 효력이 없으므로 근로기준법상 해고제한 법리(근로기준법 제23조 제1항과 제28조)가 적용되고, 더 이상 근로계약기간 만료는 근로관계의 자동소멸사유가 아니게 되었다. 특히 갱신기대권 법리에 이어 고용승계기대권⁴⁶⁾ 및 정년 후 재고용 기대권 등의 법리가 발전함에 따라 당사자의 소멸(폐업 내지

41) 대법원 2017. 10. 31. 선고 2017다22315 판결

42) 대법원 1996. 8. 29. 선고 95다5783 전원합의체 판결, 대법원 1992. 9. 1. 선고 92다26260 판결 등 참조

43) “사용자가 어떤 사유의 발생을 당연퇴직 또는 면직사유로 규정하고 그 절차를 통상의 해고나 징계해고와 달리한 경우에 그 당연퇴직사유가 근로자의 사망이나 정년, 근로계약기간의 만료 등 근로관계의 자동소멸사유로 보이는 경우”(대법원 2009. 2. 12. 선고 2007다62840 판결 등)

44) 대법원 1997. 10. 24. 선고 97누1686 판결, 대법원 1997. 11. 11. 선고 97누1990 판결, 대법원 2008. 2. 29. 선고 2007다85997 판결 등

45) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등

46) 대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결, 대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결

근로자의 사망)과 이에 준하는 것을 제외하고 ‘묻지도 따지지도 않는 근로관계의 자동소멸사유’는 더 이상 존재하지 않는다고 볼 수 있다.⁴⁷⁾ 그리고 기간제근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우 근로자가 근로계약기간이 만료된 후 갱신 거절의 유효 여부를 다룰 법률상 이익을 가지므로 근로계약기간이 만료되었다는 이유만으로 소의 이익을 부정할 수 없다는 판결 내용에⁴⁸⁾ 비추어 보면 더욱 그러하다. 당사자의 소멸 및 이에 준하는 것으로 볼 수 있는 경우를 근로관계의 자동종료사유로 보는 이유는 근로제공과 임금의 쌍무적 관계인 근로관계의 기초가 소멸되기 때문이다. 이에 따라 계약기간 만료 내지 정년을 알리는 사용자의 통지가 ‘관념의 통지’라는 위 대법원 2007다85997 판결 등은 해고의 정당성에 대한 법적 평가 이후에야 주어지는 법적 결과에 불과하므로 이에 한정하여 해석해야 하고 선제적으로 해고제한 법리의 적용 여부에서 판단할 문제가 아니라고 보아야 한다.⁴⁹⁾

47) 강선희, “해고의 서면 통지 요건과 갱신 거절 등-대법원 2021. 10. 28 선고 2021두45114 판결-”, 월간 「노동리뷰」 2022년 1월호(통권 제202호), 한국노동연구원, 2022, 133~137면 참조

48) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두59907 판결

49) 필자는 계약기간 만료 내지 정년을 알리는 사용자의 통지가 ‘관념의 통지’라는 위 대법원 2007다85997 판결 등은 당사자의 소멸과 이에 준하는 것에 적용될 뿐 그 밖의 것에 대해서는 더 이상 적용될 여지가 없어 보인다는 견해를 피력하였다[“해고의 서면 통지 요건과 갱신 거절 등-대법원 2021. 10. 28 선고 2021두45114 판결-”, 월간 「노동리뷰」 2022년 1월호(통권 제202호), 한국노동연구원, 2022, 133~137면 참조]. 즉 만약 갱신 거절의 합리적 이유 여부에 따라 ‘관념의 통지’인지 ‘해고’(‘해고와 마찬가지로’)인지가 최종적으로 결정된다면 논리 모순에 봉착하게 될 것이다. 갱신 거절의 합리적 이유는 갱신기대권이 있음을 전제로 한 것이므로 기간 만료를 통지할 때 갱신기대권이 인정될 것을 예측하여 갱신 거절의 사유를 서면으로 명시하여야 한다는 주장과 다를 바 없게 된다. 여기서 더 나아가 서면으로 명시된 갱신 거절의 사유가 합리적이라면 해고가 아니라 기간 만료로서 ‘관념의 통지’가 될 것이므로 구태여 서면으로 그 사유를 명시할 필요는 없었던 것으로 되는 모순적 순환논리에 빠지게 될 것이라는 이유였다. 그러나 관념의 통지가 법적 판단을 거쳐 주어지는 법적 결과라는 측면을 고려하면 이와 같이 판단할 필요가 없어 보이므로 견해를 수정한다.

위탁계약 등의 해지 또는 종료가 폐업이나 이에 준하는 것으로 볼 수 없다면 근로관계는 자동적으로 소멸되지 않는다. 그렇다면 근로계약 당사자 간 근로관계의 종기(終期)를 위탁계약 등이 종료할 때까지 또는 해지 시까지로 약정하였다면 이를 어떻게 해석해야 하는지, 그리고 근로계약기간을 정하면서 단서로 위탁계약 등의 종료나 해지를 근로관계의 종료사유로 정하고 있는 경우의 효력은 어떠한지, 나아가 2009년과 2017년 대법원 판결이 원용 가능한 사안은 어떠한 경우인지 등이 해결되어야 한다.

2. 2009년과 2017년 대법원 판결의 사례 검토

(1) 2009년 대법원 판결: 대법원 2009. 2. 12. 선고 2007다62840 판결⁵⁰⁾

피고는 주차관리 및 경비요원을 필요한 곳에 파견하는 것을 주요 사업으로 하는 회사이고, 원고는 2002. 2. 26. 피고에 입사하여 D센터의 미화원으로 근무하다가 2002. 12. 1.부터 D센터의 주차정산원으로 근무하였다. 2002. 2. 26. 작성된 근로계약서에 근로장소는 D로, 근로계약기간은 2002. 2. 26.부터 2002. 5. 25.까지로 기재되어 있고, 근무지 회사(건물주, 시설주 등)와 피고 간의 용역계약이 해지될 때에 원고와 피고 사이의 근로계약도 해지된 것으로 본다는 조항이 있으며, 위 계약기간 이후 별도의 근로계약을 작성하지 않고 근로관계를 유지하였다. 그러던 중 피고는 횡령에 연루된 건으로 원고를 A센터로 인사발령하였으나 이에 불응하고 무단결근하였다는 이유로 2005. 9. 28. 자 징계해고하였으나, 원고는 피고로부터 주차비 정산 등의 잔무

50) 소송의 경과: (1심) 서울중앙지방법원 2006. 12. 22. 선고 2006가합42011 판결, (2심) 서울고등법원 2007. 8. 24. 선고 2007나9896 판결, (최종심) 대법원 2009. 2. 12. 선고 2007다62840 판결, (파기환송심) 서울고등법원 2009. 7. 3. 선고 2009나19866 판결

처리를 요청받고 2005. 9. 28.부터 2005. 10. 25.까지 D센터에 출근하였다. 피고는 2005. 10. 25. 횡령 전 등의 진상규명이 완료되었다는 이유로 다시 위 일자로 원고와의 근로계약이 해지되었음을 통보하였다(원고는 협의가 없는 것으로 밝혀짐). D센터 빌딩 관리단(건물주)은 2005. 10. 31. 피고에게 2005. 11. 30. 자로 빌딩 관리계약(1년 단위로 갱신해왔음)이 해지된다고 통보하였고, 이에 따라 피고는 2005. 10. 31. 위 건물에서 근무하고 있던 피고 소속의 직원 44명에게 피고와의 근로계약이 2005. 11. 30.로 만료됨을 통보하였다.⁵¹⁾

이에 원고는 2005. 10. 25. 자 해고의 무효확인과 복직하는 날까지의 임금을 구하는 소송을 제기하였다. 1심과 2심은 해고무효확인 청구 부분에 대하여 원고와 피고 사이에 체결된 근로계약서상 “건물주와 피고와의 관리용역계약이 해지될 때 원고와 피고와의 근로계약도 해지된 것으로 본다.”라는 약정(이하 “이라 한다”)은 근로계약기간의 만료에 관한 규정으로 근로계약의 자동소멸사유를 정한 것으로 봄이 상당하고, 원고가 근무하는 건물주와 피고 사이의 관리용역계약이 2005. 11. 30. 자로 해지된 이상 피고와 원고 사이의 근로계약도 종료되었다는 이유로 원고의 해고무효확인 청구를 각하하였다. 반면 임금 청구 부분은 일부 인용하였는데 2005. 10. 25. 자 해고는 징계사유가 없음에도 징계할 의도로 행해진 것으로 무효이므로 2005. 10. 26.부터 D센터 빌딩 관리단과의 용역계약 해지로 인하여 근로관계가 종료된 2005. 11. 30.까지의 임금을 지급할 의무가 있다고 판단하였다.

대법원은 1심과 2심의 해고무효확인 청구 부분과 (원고가 패소한) 일부 임금청구 부분을 파기하고 고등법원으로 환송하였는데, “사용자가 어떤 사유의 발생을 당연퇴직 또는 면직사유로 규정하고 그 절차를 통상의 해고나 징계해고와 달리한 경우에 그 당연퇴직사유가 근로자의 사망이나 정년, 근로계약기간의 만료 등 근로관계의 자동소멸사유로 보

51) 원고 외 3명을 제외한 나머지 직원들은 모두 D센터 빌딩 관리단과 새로 용역계약을 체결한 업체에 승계되어 근무하였다.

이는 경우를 제외하고는 이에 따른 당연퇴직처분은 구 근로기준법 제 30조(현 제23조) 소정의 제한을 받는 해고라고 할 것인데, 사용자가 주차관리 및 경비요원을 필요한 곳에 파견하는 것을 주요 사업으로 하는 회사로서 그 근로자와 사이에, 근로자가 근무하는 건물주 등과 사용자 간의 관리용역계약이 해지될 때에 그 근로자와 사용자 사이의 근로계약도 해지된 것으로 본다고 약정하였다고 하여 그와 같은 해지사유를 근로관계의 자동소멸사유라고 할 수 없다.”라고 판시하였다.

파기환송심은 위 대법원 판결에 따라 원고가 패소한 부분에 대해 승소 판결을 하였다. 최종적으로 확정된 판결 내용을 정리하면 (i) 사용자가 근로자에게 행한 2005. 10. 25. 자 해고는 무효임을 확인하고, (ii) 2005. 10. 26.(해고 다음 날)부터 복직하는 날까지 임금을 지급하라는 내용이다.

이 사안에서 1·2심은 당사자 간 근로계약서를 기간제 근로계약으로 보아 위 근로관계 자동종료 약정도 근로계약의 내용에 포함되어 ‘최초로 작성된 근로계약서상의 내용과 동일한 내용으로 갱신’되었고, 위 근로관계 자동종료 약정을 ‘근로계약기간의 만료에 관한 규정’으로 봄으로써 원고의 지위를 기간제근로자로 파악하였다. 반면 대법원은 원고의 고용형태에 대해 기간제근로자가 아니라 ‘기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자’ 즉 무기계약자로 보아 주문 내용도 해고의 무효확인과 더불어 해고 다음 날부터 ‘복직 시’까지의 임금지급 명령을 하였다.

원고가 입사하면서 최초로 작성한 기간제 근로계약서(근로계약기간: 2002. 2. 26.부터 2002. 5. 25.까지) 이후로 2005. 10. 25. 자로 해고되기 전에 명시적으로 기간을 정하여 갱신한 사실이 없고, 피고가 원고를 징계해고한 사실 등에 비추어 보아 당사자 간 기간의 정함이 없는 근로계약으로 약정한 것으로 보인다. 더욱이 건물주와 피고 사이에 용역계약을 1년 단위로 갱신하여 피고와 원고 간에 근로계약기간을 정할 필요성이 있더라도 피고가 횡령에 연루된 건으로 원고를 피

고 소속 다른 사업장인 A센터로 인사발령한 사실을 보더라도 기간의 정함이 없는 계약을 체결한 것으로 봄이 타당하다. 때문에 1·2심과 같이 근로관계 자동종료 약정을 근로계약기간의 만료에 관한 규정으로 볼 수 없고, 그리고 뒤에서 서술하듯이 근로계약기간의 종기(終期)로 볼 수도 없다.

한편 위 2009년 대법원 판결은 ‘모집형 파견근로’에 대한 판단으로 그 의의가 크고⁵²⁾, 더 나아가 이와 같은 ‘파견’뿐만 아니라 아래의 2017년 대법원 판결은 아파트 위탁관리계약 등 도급계약 일반에 넓게 적용된다고 보았다는 데에 의미가 있다는 견해가⁵³⁾ 있다. 즉 이러한 견해는 원고가 파견근로자의 지위에 있고, 피고가 파견사업주, D센터 빌딩 관리단을 사용사업주로 보는 것인데 이는 용역계약을 근로자파견계약(파견근로자 보호 등에 관한 법률 제2조 제6호)으로 오인한 것으로 보인다. 구체적으로 무엇을 근거로 파견관계로 보았는지는 확인되지 않으나 예측건대 판결문에 피고에 대해 “피고는 주차관리 및 경비요원을 필요한 곳에 파견하는 것을 주요 사업으로 하는 회사”라고 적시한 부분에서 비롯된 것으로 보인다.⁵⁴⁾ 그러나 원고가 파견근로자의 지위에 있음을 확인할 만한 내용을 판결문 어디에서도 찾을 수 없고, 관련법의 적용관계 등을 종합하면 판결문에서 적시한 ‘파견하는’이라는 표현은 일반 동사로서 “일정한 임무를 주어 사람을 보내다.”라

52) 강희원, “용역계약의 해지가 근로관계의 자동소멸사유인가?”, 「노동법학」 제36호, 한국노동법학회, 2010, 113면 이하; 권오성, “아파트 위탁관리계약의 해지와 근로관계의 종료”, 「노동관계백선」 제2판, 한국노동법학회, 박영사, 2021, 196~197면.

53) 권오성, “아파트 위탁관리계약의 해지와 근로관계의 종료”, 196~197면.

54) 만약 위 견해대로 파견근로관계라면 원고는 2002. 2. 26. 입사하여 D센터에서 미화원 및 주차정산원(파견이 허용되는 근로자파견대상업무)에 2년을 초과하여 근로하였으므로 피고로부터 해고되기 전에 이미 2006년 개정되기 전의 파견법에 따라 사용사업주에 해당하는 D센터 빌딩 관리단에 고용의제되었을 것이다. 그리고 D센터 빌딩 관리단과 피고 사이에 체결한 관리용역계약은 위장된 것으로 그 실질을 근로자파견계약이 될 것이다.

는 의미의 ‘파견하다’에 불과하다.

(2) 2017년 대법원 판결: 대법원 2017. 10. 31. 선고 2017다 22315 판결⁵⁵⁾

피고는 B아파트의 위탁관리업무를 하는 회사이고, 원고는 2015. 12. 1. 피고와 근로계약을 체결하면서 근로장소는 B아파트, 직책은 경비원으로 하였으며, 앞서 시용계약의 사례에서 보았듯이 근로계약서의 상단에 ‘근로계약기간’은 “2015. 12. 1.부터 2016. 2. 29.까지(3개월)로 기한의 정함이 있는 것으로 하며, 계약기간 종료 또는 계약기간 중이라도 피고와 사업장 사이의 위·수탁(도급)계약이 해지(종료)되는 경우 근로계약은 자동종료되는 것”으로, 하단에 ‘기타 조건’으로 “입사 후 최초 3개월의 수습기간을 거쳐 정식 직원으로 임명되며 이와 관련한 사항은 취업규칙에 따르는 것”으로 정하였다. 피고는 원고에게 2016. 2. 29. 자 기간 만료를 통지하였고, 이에 원고가 해고무효확인 소를 제기하였다. 그러던 중 B아파트의 사업주체와 피고 간에 체결한 공동주택 위탁관리계약이 2016. 5. 31. 종료되었다.

앞서 언급하였듯이 모든 심급의 법원은 위 계약이 시용계약임을 전제로 해고의 서면통지 절차를 위반하여 무효라고 판단하였다. 그러나 1·2심은 위 근로관계 자동종료 약정에 따라 B아파트에 대한 위탁관리계약이 종료됨에 따라 근로관계도 종료된 것으로 보아야 하므로 해고의 무효확인 청구 부분은 이미 종료된 근로관계에 따라 확인의 이익이 없어 각하하고, 이에 따라 해고일(2016. 3. 1.)부터 위탁관리계약 종료일인 2016. 5. 31.까지의 임금(일부 중간수입 공제)을 지급하라고 명하는 한편 2016. 6. 1.부터의 임금청구는 기각하였다. 그러나 대

55) 소송의 경과: (1심) 서울남부지방법원 2016. 11. 11. 선고 2016가합1633 판결, (2심) 서울고등법원 2017. 5. 26. 선고 2016나210391 판결, (최종심) 대법원 2017. 10. 31. 선고 2017다22315 판결, (파기환송심) 서울고등법원 2018. 3. 7. 선고 2017나28919 판결

법원은 근로자가 패소한 부분에 대하여, 위와 같이 근로관계 자동종료 약정이 있더라도 그와 같은 해지사유를 근로관계의 자동소멸사유라고 할 수는 없다는 위 2009년 대법원 판결을 전제로 위탁관리계약이 종료되었더라도 원고와 피고 사이의 근로관계가 당연히 종료된 것으로 단정할 수 없다며 원심을 파기하고 환송하였다.

파기환송심은 위 대법원 판결에 따라 원고가 패소한 부분에 대해 승소 판결을 하였다. 최종적으로 확정된 판결 내용(원고는 대법원의 파기환송 후 해고무효확인 청구 부분을 취하하고 미지급 임금 청구를 감축하고, 퇴직금 및 지연손해금 청구를 추가함)은 (i) 해고일(2016. 3. 1.)부터 위탁관리계약 종료일인 2016. 5. 31.까지의 임금(1·2심에서 확정된 부분), (ii) 2016. 6. 1.부터 2017. 11. 30.(원고의 정년퇴직일⁵⁶⁾)까지의 임금, 퇴직금 및 지연손해금 지급을 명하였다.

위 대법원 및 파기환송심은 원고에 대한 본채용 거부가 무효이므로 B아파트에 대한 위탁관리계약이 종료되었다고 원고는 피고 소속으로 정년까지 근무하였을 것으로 보았다. 이는 앞서 살펴보았듯이(II. 1.) 시용기간 종료 후 본 채용되는 경우 근로계약기간을 정하는 등의 별도의 약정이 없다면 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 보아야 하므로 이 사안의 경우에도 마찬가지이다.

3. 근로관계 종료 약정의 유효성

계약자유의 원칙에 따라 근로계약 당사자 사이에 근로관계의 종료에 대해 약정할 수 있으나 근로자가 직장을 얻기 위하여 종속적 지위에서 어쩔 수 없이 불리한 근로계약을 체결하고 근로자의 의사에 반

56) 피고의 취업규칙 제43조 “경비직원의 정년은 만 65세로 한다. 정년퇴직일자는 정년에 도달하는 날에 해당하는 달의 말일로 한다.”라고 규정하고 있고, 원고는 2017. 11. 19. 만 65세가 되었다. 따라서 원고가 피고의 해고가 없었다면 2017. 11. 30.에 정년퇴직하였을 것이다.

하여 근로관계가 종료되는 경우가 생길 수 있다. 따라서 당사자 간 합의해지, 당사자 소멸(사망이나 폐업) 및 이에 준하는 자동소멸사유를 제외하고 실제 사업장에서 불리는 명칭 등과 관계없이 근로자의 의사에 반하여 사용자의 일방적 의사에 의하여 이루어지는 근로관계 종료는 해고로써 근로기준법 제23조 제1항의 해고제한 법리를 적용받는다. 아래에서는 근로관계의 종료에 대한 약정 중 근로계약의 종기(終期)에 대한 약정과 근로관계의 종료사유를 위탁계약 등의 중도해지 및 종료로 정한 것을 위주로 살펴본다.

(1) 근로관계의 종기(終期)에 대한 약정(기간제 근로계약)

당사자는 사적자치의 원칙에 따라 근로관계의 시기(始期)와 종기(終期), 즉 근로계약기간에 대해 자유로이 약정할 수 있다. 이러한 근로계약기간은 근로관계의 존속기간이므로⁵⁷⁾ 처분문서인 근로계약서의 문언에 따라 특별한 사정이 없는 한 근로계약기간이 끝나면 그 근로관계는 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 당연히 종료함이 원칙이다. 다만 예외적으로 기간의 정함이 단지 형식과 불과하다는 사정이 인정되는 경우⁵⁸⁾, 갱신기대권이 인정되고 합리적 이유 없이 갱신을 거절하는 경우⁵⁹⁾ 및 기간제법상 사용기간의 제한을 받는 경우 등은 해고제한 법리가 적용되어 기간 만료로 인한 근로관계 종료는 법적 보호를 받을 수 있다.

근로계약기간은 입사일이 시기(始期)이고, 근로관계가 종료되는 종기(終期)를 정하는데 종기는 ‘○○○○년 ○○월 ○○일까지’라고 하여 도래할 것이 확실한 확정기한으로 정하는 것이 일반적이다. 그러나 근로계약의 종기를 이와 같이 날짜를 특정하지 않고 ‘공사 종료

57) 대법원 1996. 8. 29. 선고 95다5783 전원합의체 판결

58) 대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두16901 판결 등

59) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등

시’, ‘공종 종료 시’ 또는 ‘프로젝트 종료할 때까지’ 등으로 정하거나, 특정한 날짜를 종기로 정하면서 단서나 별도 규정으로 근로계약이 자동으로 연장되거나 갱신되는 경우 ‘사업 종료 시’까지 등으로 약정하는 경우 등이 있는데 이러한 약정의 유효성에 대해 아래에서 검토하도록 한다.

첫째, 근로계약의 종기를 ‘공사 종료 시’, ‘공종 종료 시’⁶⁰⁾, ‘사업이 완료할 때까지’ 또는 ‘프로젝트 종료할 때까지’ 등으로 정한 경우이다. 사용자가 일정 기간 후 종료될 것이 명백한 한시적인 사업 또는 업무(기간제법 제4조 제1항 단서 제1호의 ‘사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우’)에 종사할 근로자를 고용하면서 위 사업 또는 업무가 끝날 것으로 예상되는 특정 시점까지로 계약기간을 정하지 않고 ‘사업 또는 특정한 업무가 끝날 때까지’ 또는 ‘프로젝트 종료할 때까지’로 근로계약의 종기로 정하는 경우이다. 일반적으로 사업의 완료 등에 필요한 기간을 사전에 명확히 하는 것이 불가능하거나 곤란한 경우 또는 인력수급, 경제환경의 변동, 기후변화에 따른 공정 지연, 계절적 요인 등 당초 예측할 수 없는 상황이 발생할 우려가 있어 근로계약의 종기를 따로 기간으로 정하지 않고 위와 같이 사업이 완료할 때까지 등으로 약정하는 경우이다. 공사·공종 및 사업 등이 일정 기간 후 객관적으로 종료될 것이 명백하므로 특정 시점까지로 정한 것과 마찬가지로 그 유효성이 인정된다.

둘째, 근로계약기간을 특정 시점까지로 정하면서 단서나 별도 규정으로 근로계약이 자동으로 연장되거나 갱신되는 경우 ‘사업 종료 시’까지 등으로 약정하는 경우이다. 예를 들면 근로계약기간을 ‘입사일부터 1개월’이나 ‘2022. 7. 1.~2022. 12. 31.’ 등으로 특정하면서 “근로계약기간이 만료된 후에도 ‘갑’과 ‘을’ 간에 이의가 없다면 별도의

60) 건설공사에서 공종은 미장공사, 도장공사, 철근콘크리트공사, 방수공사 등 공사의 종류를 말한다. 건설공사의 공정은 시간에 따른 공사의 진척도를 의미한다.

계약절차 없이 동일한 계약이 갱신된 것으로 보되, ‘을’이 수행하는 공종이 종료할 때에 근로계약도 종료한다.”, “단, 근로계약이 갱신된 경우라 하더라도 근로계약의 최대기간은 공사현장의 ‘을’이 수행하던 공종 종료일을 초과하지 못한다.”라는 취지로 약정하는 것이다. 이러한 특약은 근로계약이 자동으로 연장되거나 갱신되더라도 근로자가 수행하는 공종 종료일 등 ‘사업의 종료일 또는 특정 업무의 완성일’을 초과하여 갱신할 수 없다는 것이므로 갱신의 최대한도를 약정한 것으로 봄이 타당하다.⁶¹⁾ 이는 근로자에게 불리한 근로계약도 아니고, 근로자가 불안정한 지위에 빠질 우려도 없으므로 이러한 특약의 유효성은 인정된다. 특약으로 정한 내용인 ‘사업 종료 시’는 위 첫 번째와 마찬가지로 일정 기간 후 객관적으로 종료될 것이 명백한 사업으로 도래할 것이 확실한 확정기한을 말하는 것이며, 사용자의 주관적 사정에 따른 사업의 종료를 말하는 것이 아니다.

(2) 위탁 등 아웃소싱계약의 중도해지나 종료를 근로관계의 종료사유로 약정한 경우

근로계약으로 근로계약기간 중이라도 위·수탁관리계약 등이 종료 또는 중도에 해지되거나 무단결근을 5일 이상 한다거나 업무수행능력이 부족하거나 신체·정신상의 장애 및 노령으로 근로능력이 현저히 상실되었다고 판단되는 경우 등을 근로계약의 자동종료사유로 정하는 경우가 있다. 당사자의 소멸 및 이에 준하는 사유가 아니라면 근로관계의 자동종료 약정은 유효하지 않음은 앞서 살펴보았으나 이러한 사유 중 근로계약기간 중이라도 위탁 등 아웃소싱계약이 종료되거나 중도해지된 때를 근로계약의 종료일로 본다고 약정한 경우 이를 근로계약의 종기(終期)에 대한 약정인지 혹은 근로관계의 종료사유에 대한

61) 이러한 특약이 없더라도 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정될 경우에도 갱신기대의 최대한도는 ‘사업의 종료일 또는 특정 업무의 완성일’까지이다.

약정인지가 문제될 수 있다. 여기서 특별한 언급이 없는 경우에는 기간제근로자임을 전제로 논의를 전개한다.⁶²⁾

첫째, 근로계약기간을 특정 시점으로 정하거나 따로 기간을 특정하지 않고 사업의 종료 시까지 등으로 정하면서 단서나 별도 규정으로 근로계약기간 중이라도 위탁계약 등이 (중도)해지될 경우 위탁계약 해지일을 근로계약 종료일로 한다는 취지로 정하는 경우이다. 이러한 약정에 대해 근로계약 당사자가 근로계약기간 중이라도 위탁계약이 해지될 경우 위탁계약의 해지일을 근로계약기간의 종기로 앞당기는 특약을 한 것으로 볼 여지도 있다(위의 2009년과 2017년 대법원 판결의 사안에서 이와 같은 약정이 있었고, 2009년 대법원 판결의 원심이 이러한 판단을 한 것으로 보인다). 그러나 이러한 약정은 두 가지 측면에서 그 유효성을 인정하기 어려운데, 하나는 이러한 약정은 위 2009년 대법원 판결의 원심과 같이 근로계약기간에 대한 특약으로 보기 어렵다는 점이다. 즉 근로계약기간의 종기(終期)는 ‘○○○○년 ○○월 ○○일까지’라든지 ‘사업의 종료 시까지’(‘공사 종료 시’, ‘공종 종료 시’, ‘프로젝트 종료할 때까지’) 등으로 도래할 것이 확실한 확정기한으로 정해야 한다. 그러나 위의 ‘근로계약기간 중이라도 위탁계약이 해지될 경우’는 장래에 발생 여부가 불확실한 사실이므로 이는 근로관계의 소멸을 장래의 불확실한 사실에 의존하게 하는 법률행위로써 일종의 조건(條件)으로 보아야 한다. 이와 같은 조건은 근로계약기간에 대한 약정이 아니라 근로관계의 종료 사유이므로 앞서 언급하였듯이 당사자의 소멸 및 이에 준하는 사유가 아니라면 근로기준법 제23조(제24조 포함)의 ‘정당한 이유’의 통제를 받아야 한다. 이러한 측면에서 위 2009년 및 2017년 대법원의 판결 내용과 같이 ‘근로계약기간의 만료 등 근로관계의 자동소멸사유로 보이는 경우를 제외하고는’ 근로기

62) 예컨대 근로계약의 종기가 정년인 무기계약자인 경우에는 위탁계약 등이 종료되거나 해지되더라도 다른 사업장으로 배치하거나 근로기준법 제24조 경영상 이유에 의한 해고의 요건을 갖추어 해고하여야 한다.

준법 제23조 소정의 제한을 받는 해고라고 할 것이므로 “사용자가 주차관리 및 경비요원을 필요한 곳에 파견하는 것을 주요 사업으로 하는 회사로서 그 근로자와 사이에, 근로자가 근무하는 건물주 등과 사용자 간의 관리용역계약이 해지될 때에 그 근로자와 사용자 사이의 근로계약도 해지된 것으로 본다고 약정하였다고 하여 그와 같은 해지 사유를 근로관계의 자동소멸사유라고 할 수 없다.”라고 판시한 것이다. 물론 이 사안 모두 중국적으로 기간제근로자가 아니라고 보았는데 기간제근로자라 하더라도 달리 판단되지 않는다(구제의 범위에서 차이가 있을 뿐이다). 다른 하나는 위와 같은 근로관계 자동종료 약정은 근로자의 귀책사유에 속하지 않는 경영위험을 근로자에게 일방적으로 부담하게 하는 약정으로 그 유효성을 인정하기 어렵다. 위탁계약 등의 해지 사유가 사용자의 귀책사유(민법 제538조)에서 비롯된 것이 아니라도 사용자의 세력범위 안에서 발생한 경영장애 내지 경영위험은 근로기준법 제46조 사용자의 귀책사유에 해당한다고 볼 수 있다.⁶³⁾

예컨대 건설업에서 기간제 근로계약의 종기를 ‘공중 종료일까지’(A) 등으로 정하면서 단서나 별도 규정으로 “근로계약기간 중이라도 천재·사변, 사용자의 귀책사유에 해당하지 않는 발주처의 공사중단·설계변경 등의 불가피한 사유로 ‘을(근로자)’이 수행하던 공중이 종료된 경우(B)에는 그때를 계약만료일로 한다.”라고 정하는 경우가 있다.⁶⁴⁾ 얼핏 보면 A의 ‘공중 종료일’에는 사용자의 귀책사유에 해당하지 않는 불가피한 사유로 인하여 해당 공중이 종료된 경우(B)를 포함하여 약정한 것으로 볼 여지도 있다. 그러나 A의 ‘공중 종료일’은 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 의미하는 반면, B의 해당 공중이 종료된 경우는 공사의 진행과정을 나타내는 예정공

63) 위탁계약의 해지로 인해 사용자가 그 업무를 수행하던 근로자를 다른 사업장으로 배치하는 것이 불가능하여 휴업한 경우, 근로기준법 제46조에 따라 천재·지변 등의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우가 아니라면 위탁계약의 해지 등은 사용자의 귀책사유에 속하므로 휴업수당을 지급해야 한다.

64) 고용노동부에서 작성한 주40시간 기간제근로자용 ‘건설현장 표준근로계약서’이다.

정표상 해당 공종의 종료일이 공사의 빠른 진척으로 예상했던 종료일보다 앞당겨져 종료된 것이 아니라 발주처의 공사중단·설계변경 등의 사유로 인한 해당 공종의 종료는 중도해지와 마찬가지로 장래에 발생 여부가 불확실한 사실로 도래할 것이 확실한 확정기한이 아니다. 따라서 위와 같은 약정이 있더라도 이로 인해 근로관계가 자동적으로 종료한다고 보기 어렵고, 위 약정에 따라 사용자의 귀책사유뿐만 아니라 발주처의 공사중단·설계변경 등의 사유로 인해 해당 공종이 종료된 경우에는 적어도 예정공정표상의 해당 공종의 종료일까지는 근로관계가 유지된 것으로 보아야 한다.⁶⁵⁾ 반면 빠른 공사의 진척으로 예정공정표상 해당 공종의 종료일보다 앞서 종료한 경우는 A의 ‘공종 종료일’에 지나지 않는 것으로 판단해야 한다.

한편 위와 같은 약정(‘근로계약기간 중이라도 위탁계약이 해지될 경우’)을 하였더라도 이것이 장래에 발생 여부가 불확실한 사실이 아닐 경우, 예컨대 위탁계약의 해지가 확정되었으나 해지일이 유동적인 상황에서 위탁계약 해지일까지의 업무공백을 방지할 목적으로 근로계약기간을 대략으로 정하면서 해지일을 종기로 정한 경우 그리고 당사자가 이를 인지하고 명시적으로 합의했다면 이는 근로계약기간의 만료일을 정한 것으로 볼 수 있다.

둘째, 근로계약기간(특정 시점 또는 특정 업무의 종료 시까지)을 정하면서 단서나 별도 규정으로 근로계약기간 만료일 전이라도 해당 업무 등이 종료되는 경우 해당 업무 종료일을 근로계약 종료일로 한다는 취지로 정하는 경우이다. 이와 같은 경우에도 해당 업무 등이 종료된 원인이 중도해지와 같다면 첫 번째의 경우와 마찬가지로 판단해야 한다.

예컨대 아파트입주자대표회의와 수탁업체 사이의 위·수탁관리계약 기간이 2020. 5. 1.~2022. 9. 30.임에도 근로계약으로 2021. 10. 1.~2022.

65) 이러한 측면을 고려하면 고용노동부의 ‘건설현장 표준근로계약서’에서 논란의 소지가 있는 부분을 수정할 필요가 있어 보인다.

12. 31.로 정하면서 단서로 근로계약기간 중이라도 위·수탁관리계약이 중도해지되거나 노령으로 근로능력이 현저히 상실되었다고 판단되는 경우에는 근로계약은 자동종료로 해지된다고 정한 경우 사용자가 2022. 9. 30. 위·수탁관리계약이 종료됨에 따라 근로자에게 근로계약도 같은 날 종료된다고 통보하였다. 이와 유사한 사례에서 하급심은⁶⁶⁾ 위 2017년 대법원 판결을 전제로 사용자가 2022. 9. 30. 근로관계가 종료된다고 통보한 것은 실질적으로 해고에 해당하고 해고의 정당성이 없으므로 무효이되 근로계약기간 만료일인 2022. 12. 31.까지 휴업수당을 지급하라고 명하였다. 사용자는 위·수탁관리계약기간이 2022. 9. 30.까지인 것을 알고 있음에도 근로계약을 2022. 12. 31.까지로 체결하였다면 위·수탁관리계약기간의 만료로 해당 사업장의 업무가 종료되더라도 근로자를 다른 사업장으로 배치전환 등의 조치를 취했어야 한다.

반면 ‘근로계약기간 만료일 전이라도 해당 업무 등이 종료되는 경우’가 위와 같은 경우가 아니라면 달리 판단해야 하는데, 예컨대 근로계약기간을 “입사일부터 ○○ 공중 종료예정일(2022. 12. 31.)까지, 다만 ○○ 공중이 예정일보다 빨리 완성된다면 그 완성일까지로 한다.”라고 정한다면 그 완성일이 근로계약의 종기가 될 것이다. 위 ‘2022. 12. 31.’은 ○○ 공중의 종료예정일에 불과하기 때문이다.

Ⅳ. 아웃소싱업체의 변경 등과 근로관계

1. 아웃소싱업체의 변경 등과 근로관계의 승계

기업이 기존에 직접 처리하던 업무를 위임이나 도급의 형식으로 외부업체에게 맡겨 수행하도록 하는 아웃소싱(outsourcing, 외주화)의

66) 서울중앙지방법원 2019. 1. 17. 선고 2018가단38841 판결. 이 판결은 2심(서울중앙지방법원 2019. 9. 5. 선고 2019나8374 판결)에서 상시근로자 수 5명 미만 사업장으로 근로기준법 제23조가 적용되지 않는다는 이유로 취소되었다.

경우 또는 아웃소싱업체(수탁업체 및 용역업체)의 변경이 있는 경우 근로관계가 승계되는지 여부에 대해 종래에는 사업양도(사업이전)의 법리로 해결하고자 하였다. 기업변동의 유형별로 상법의 영업양도, 합병, 분할 규정을 유추적용하거나 해석론으로 해결하였고, 특히 아웃소싱으로의 전환 및 아웃소싱업체의 변경이 영업양도(사업양도, 사업이전)인지 여부가 문제시되었는데 사업양도인지에 따라 근로관계 승계 여부가 판가름이 나기 때문이다. 대법원은 “영업의 양도라 함은 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것으로서 영업의 일부만의 양도도 가능하고, 이러한 영업양도가 이루어진 경우에는 원칙적으로 해당 근로자들의 근로관계가 양수하는 기업에 포괄적으로 승계된다.”라고 판시하면서⁶⁷⁾, “영업양도 당사자 사이에 근로관계의 일부를 승계의 대상에서 제외하기로 하는 특약이 있는 경우에는 그에 따라 근로관계의 승계가 이루어지지 않을 수 있으나, 그러한 특약은 실질적으로 해고나 다름이 없다 할 것이므로, 근로기준법 제23조 제1항 소정의 정당한 이유가 있어야 유효하다 할 것이며, 영업양도 그 자체만을 사유로 삼아 근로자를 해고하는 것은 정당한 이유가 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다 할 것이다.”라고⁶⁸⁾ 판시하였다(원칙승계설). 즉 ‘사업양도’의 개념에 해당한다면 그 법적 효과로서 근로관계가 승계되기 때문에 아웃소싱으로의 전환 및 아웃소싱업체의 변경이 사업양도인지 여부가 종래에 핵심이었다.⁶⁹⁾ 그러나 법원은 일관되게 아웃소싱으로의 전환(예컨대 아파트 등의 건물관리형태가 자치관리에서 위탁관리로 변경하는 경우 등)이든 아웃소싱업체 간의 변경이든 위임계약 또는 도급계약에 불과하고 사업양도에 해당하지 않는다는 입장이다.⁷⁰⁾ 법원이

67) 대법원 2001. 7. 27. 선고 99두2680 판결 등

68) 대법원 1994. 6. 28. 선고 93다33173 판결 등

69) 학계도 이를 사업양도로 접근하는 시도가 있었고 대표적으로 김기선, 「아파트 관리를 둘러싼 노동법적 분쟁에 관한 연구」, 한국노동연구원, 2019.; 김기선·전형배·최석환, 「아웃소싱과 고용관계의 법제도 개선방안」, 한국노동연구원, 2012.이 있다.

이와 같은 태도를 보이는 것은 법리상 부득이해 보인다.

기업이 기존에 직접 처리하던 업무를 외주화하거나, 외주주였던 업무를 직접 처리하는 직영 시 및 외주업체를 변경하는 것은, 기업변동의 한 유형으로써 사업 자체의 양도를 통해 ‘사업주체’가 변경되는 것이 아니라 사업주체는 변경 없이 그대로 존속하면서 위임이나 도급 등을 통해 해당 업무의 ‘관리주체’가 변경되는 것에 불과하기 때문에 법리상 ‘사업양도’로 보기 어려운 측면이 있다. 그러나 현실적으로 보면 아웃소싱업체의 입장에서 위탁기간에 한정하여 위탁업무를 수행하여 한시적일지라도 그 업무를 수행하는 근로자는 아웃소싱업체만 변경된 채로 동일한 업무를 수행해왔고, 향후로도 그러할 것이라고 신뢰하기 때문에 자신의 고용이 한시적이라고 생각하지 않을 수 있다. 위와 같이 사업양도와 관련된 법리를 아웃소싱 상황에 적용하는 데에 한계가 있을 수밖에 없는데, 최근 용역업체의 변경 시 고용승계기대권을 인정하는 판례 법리가 생김으로써 이러한 한계를 어느 정도 극복할 것으로 보인다.

2. 고용승계기대권 법리

(1) 대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결

고용승계기대권을 명시적으로 인정하는 대법원 판결이 지난 2021.

-
- 70) 대법원 1997. 6. 24. 선고 96다2644 판결, 대법원 2000. 3. 10. 선고 98두4146 판결 (아파트 관리업무 인계·인수의 경위와 원고가 공개입찰의 방법에 의하여 입주자대표회의와의 사이에 새로운 경비용역계약을 체결한 점에 비추어 원고의 경비업무와 □□산업의 종전 경비업무의 내용이 동일하다는 점만으로는 원고가 영업양도에 준하여 종전의 근로관계를 승계하였다고 볼 수 없다는 이유로 배척한 원심을 수긍하였다), 서울고등법원 2003. 10. 16. 선고 2002누3364 판결(대법원 2004. 3. 25. 자 2003두13991 판결에서 심리불속행 기각으로 확정) 등. 한편 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010다92148 판결은 “공동주택 입주자들이 공동주택을 자치관리 방식으로 관리하다가 주택법에 정한 절차에 따라 주택관리업자에게 위탁관리하기로 하여 관리방식을 변경하는 것은 사업의 폐지라고 볼 수 없고, 그로 인한 관리직원의 해고는 경영상의 필요에 의한 해고로서 정리해고에 해당한다고 봄이 상당하다.”라고 판시하였다.

4. 29. 나온 이래 이를 따르는 판결이⁷¹⁾ 나오면서 실무에서 이를 주장하는 사례가 증가하고 있다.

대법원 2016두57045 판결은⁷²⁾ 고용을 승계하기로 하는 명시적인 약정이 있었던 사안으로 새로운 용역업체에게 고용승계의무를 인정하는 것이 당연해 보일 수 있으나 그럼에도 이 판결은 고용승계의무에 대한 판단기준을 정식화시켰다는 측면에서 큰 의의가 있다. 한국○○○○ 주식회사(이하 ‘원사업주’라 함)와 새로운 용역업체X는 “특별한 사정이 없는 한 현재 근무하고 있는 종업원을 고용승계 및 용역계약 기간 중 고용유지 하여야 한다.”라는 취지의 용역계약서 및 청소용역 시방서를 체결하였음에도 종전 용역업체에서 근무하던 근로자들(용역업체만 바뀐 채로 11년 9개월가량에서 17년 6개월가량을 같은 발전소에 근무)의 고용승계를 거부하였다. 그런데 용역업체X는 2007년에도 원사업주와 용역계약을 체결하고 고용을 모두 승계한 사실이 있었다. 이에 대법원은 “도급업체가 사업장 내 업무의 일부를 기간을 정하여 다른 업체(이하 ‘용역업체’라 고 한다)에 위탁하고, 용역업체가 위탁받은 용역업무의 수행을 위해 해당 용역계약의 종료 시점까지 기간제근로자를 사용하여 왔는데, 해당 용역업체의 계약기간이 만료되고 새로운 용역업체가 해당 업무를 위탁받아 도급업체와 사이에 용역계약을 체결한 경우, 새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성되었다면, 특별한 사정이 없는 한 근로자에게는 그에 따라 새로운 용역업체로 고용이 승계되리라는 기대권이 인정된다. 이와 같이 근로자에게 고용승계에 대한 기대권이 인정되는 경우 근로자가 고용승계

71) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결, 대법원 2021. 6. 24. 선고 2017두72560 판결, 대법원 2021. 7. 8. 선고 2020두40945 판결 등

72) 이 부분은 강선희, “용역업체 변경 시 고용승계기대권-대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결-”, 월간 「노동리뷰」 2021년 7월호(통권 제196호), 한국노동연구원, 2021. 수정하여 정리하였다.

를 원하였는데도 새로운 용역업체가 합리적 이유 없이 고용승계를 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 근로자에게 효력이 없다. 이때 근로자에게 고용승계에 대한 기대권이 인정되는지 여부는 새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항을 포함하고 있는지 여부를 포함한 구체적인 계약내용, 해당 용역계약의 체결 동기와 경위, 도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행, 위탁의 대상으로서 근로자가 수행하는 업무의 내용, 새로운 용역업체와 근로자들의 인식 등 근로관계 및 해당 용역계약을 둘러싼 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”라고 판시하였다.⁷³⁾ 그간 대법원은 갱신기대권 법리를 통해 기간제근로자의 고용종료를 보호하였고, 이를 정규직 전환기대권으로 발전시켰으며, 여기서 한 발 더 나아가 고용승계기대권으로 끌어올린 것이다(중앙노동위원회가⁷⁴⁾ ‘고용관계의 승계에 대한 기대권’의 용어를 처음 사용하였고, 대법원이 이를 수용한 것이다). 고용승계기대권은 변경된 새로운 사용자를 대상으로 전개하였다는 데에 큰 의의가 있고, 이러한 측면에서 앞선 기대권과 달리 더욱 엄격한 판단요소를 내세운 것으로 볼 수 있다. 대법원은 고용승계기대권의 일차적 판단요소로 “새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항을 포함하고 있는지 여부를 포함한 구체적인 계약내용”(판단요소①)을 들고 있다. 계약은 지켜야 한다는 로마법의 격언(“pacta sunt servanda”)을 굳이 언급하지 않아도, 제3자를 위한 계약인지를 따질 필요도 없이 당연한 논리적 귀결이다. 앞선 기대권 법리에서는 위 판단요소①과 같은 ‘그러한 규정이 없더라도’ 관행 등의 여러 사정을 종합하여 갱신기대권 인정 여부를 판단하였는데, 이 판

73) 원심인 대전고등법원(2016. 10. 7. 선고 2016누11696 판결)은 용역업체X의 고용승계의무를 ‘제3자를 위한 계약’(민법 제539조) 법리에서 찾았으나 대법원은 위와 같은 내용으로 판시하면서 용역업체X의 상고를 기각하였는데 원심에서 전개한 ‘제3자를 위한 계약’의 법리보다 ‘갱신기대권’의 법리를 원용하였다.

74) 중앙노동위원회 2015. 2. 16. 판정 2014부해1342

결은 위 두 가지 판례 법리를 원용하면서도 이와 같은 표현 없이 “해당 용역계약의 체결 동기와 경위, 도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행, 위탁의 대상으로서 근로자가 수행하는 업무의 내용, 새로운 용역업체와 근로자들의 인식 등”(판단요소⑥)과 나란히 열거하고 있다. 이러한 사실을 미루어 보면 대법원 2016두57045 판결은 판단요소①과 같은 고용승계와 관련된 명시적 약정이 없는 경우 새로운 용역업체에게 고용승계의무를 인정하기 어렵다고 보는 것으로 평가할 수 있다. 이러한 이유로 대법원 2016두57045 판결의 확장가능성은 그리 크지 않을 것으로 보이나 현실에서 적극적으로 적용할 필요가 있다. 앞서 서술하였듯이 근로자 입장에서 보면 용역업체 명칭만 변경되었을 뿐 그 자리에서 항상 같은 업무를 수행하는데 근로관계 승계 법리가 적용되는 사업양도가 아니라는 이유로 업체의 변경만으로 일자리를 상실한다는 것은 납득하기 어렵기 때문이다. 이러한 측면에서 입법적 해결방안을 모색할 필요도 있다.⁷⁵⁾

(2) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결⁷⁶⁾

이 대법원 판결은 고용을 승계하기로 하는 명시적인 약정이 없더라도 관행을 근거로 고용승계기대권을 인정한 판결이다. 근로자A는 2009. 10. 1.부터 대한석탄공사 장성광업소에서 장성광업소와 선탄관리작업 용역계약을 체결한 여러 용역업체에서 선탄작업을 수행하던 중 2018. 3. 29. 용역업체X로부터 승계 거절된 사안이다.⁷⁷⁾ 대법원은

75) 2021. 5. 17. 송옥주 국회의원이 대표 발의한 ‘사업이전에서의 근로자 보호 등에 관한 법률안’처럼 영업양도뿐만 아니라 도급·용역업체 등의 변경을 포함하여 사업의 전부 또는 일부가 이전되는 경우 근로관계를 포괄적으로 승계하도록 입법화하는 해결방안을 모색할 수 있다.

76) 이 부분은 강선희, “용역업체 등의 변경 시 관행 등을 근거로 한 고용승계기대권 및 두 가지 의문-대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결-”, 월간 『노동리뷰』 2021년 9월호(통권 제198호), 한국노동연구원, 2021. 수정하여 정리하였다.

77) 근로자A의 근무이력은 아래와 같다.

위 대법원 2016두57045 판결을 전제하면서 3가지 논거를⁷⁸⁾ 근거로 고용승계의무를 인정하였다. 앞서 대법원 2016두57045 판결에 대해 명시적 약정이 없더라도 관행 등의 여러 사정을 종합하여 고용승계기대권을 인정할 수 있을지에 대한 의구심을 표명하였는데, 이 대법원 2020두45308 판결로 그러한 우려는 일부 덜어낸 듯하다.

대법원 2020두45308 판결과 대법원 2016두57045 판결의 사안에서 공통점이 있다면 새로운 용역업체가 예전에도 도급업체 사업장에서 용역을 받은 적이 있어 고용승계 관행을 알았고, 근로자들이 장기간(9년 정도에서 17년간) 근무하였다는 사정이다. 여기서 2가지 의구심이 있는데, 하나는 같은 사업장에서 장기간 근로계약을 반복하여 갱신하거나 체결하면서 오랫동안 근로한 근로자와 그렇지 않은 근로자 사이에 고용승계기대권의 인정 여부를 달리 판단할 수 있는지 여부이고, 다른 하나는 고용을 승계하는 관행의 존재만(‘도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행’)으로 새로운 용역업체에게 고용승계의무를 인정할 수 있는지 여부이다. 이는 항을 나누어 살펴본다.

(3) 고용승계기대권 판단기준(고용승계약정이 없는 경우)

첫째, 같은 사업장에서 장기간 근로계약을 반복하여 갱신하거나 체결하면서 오랫동안 근로한 근로자와 그렇지 않은 근로자 사이에 고

근무기간	2009. 10. 1.~ 2011. 9. 30.	2011. 10. 1.~ 2015. 3. 31.	2015. 4. 1.~ 2017. 3. 31.	2017. 4. 1.~ 2018. 3. 31.	2018. 4. 1.~ 2018. 12. 31.
소속 용역업체	U	W	X	Y	X

78) 근로자A는 여러 차례 용역업체가 바뀌는 과정에서도 근로기간의 단절 없이 고용관계의 승계를 인정받아 계속 근무하였고(2015년 용역업체X에 고용승계 되어 근무한 적도 있음), 용역업체X는 이전 용역업체Y의 선탄작업 근로자 11명 가운데 근로자A를 제외한 10명에 대한 고용을 모두 승계한 사실에 비추어 기존 용역업체의 근로자에 대한 고용승계의무가 있다는 점을 인식하고 있었으며, 장성광업소의 용역업체에서 근로하면서 본인의 의사에 반하여 고용승계가 거부된 근로자는 없었던 것으로 보인다는 점이다.

용승계기대권의 인정 여부를 달리 판단할 수 있는지 여부이다. 예컨대 근로자들(10여 명)이 용역업체의 변경에도 같은 사업장에서 같거나 유사한 업무를 하며 근로자A는 20년간, 근로자B는 10년간, 나머지는 짧게는 3개월에서 많게는 5년을 계속 근무한 경우 10년 내지 20년간 근무한 근로자A·B에게만 고용승계기대권이 인정된다고 볼 여지도 있다. 그러나 고용승계기대권은 근로자 개별이 갖는 ‘주관적 기대’가 아니라 ‘해당 근로관계 및 해당 용역계약을 둘러싼 여러 사정’을 통해 인정되는 ‘객관적 기대’이므로 일부 근로자가 단기간 근로하였더라도 여러 사정을 종합하여 보았을 때 고용을 승계하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 객관적으로 형성되었다면 기대권을 인정할 수 있을 것으로 보인다.⁷⁹⁾ 역으로 근로자의 일부가 장기간 근무한 사정만으로 새로운 용역업체에게 근로자의 고용을 승계할 의무를 인정하기 어려울 수 있고, 장기간 근무한 해당 근로자에 대해서만 고용승계기대권을 인정하는 것도 아닐 수 있다. 새로운 사용자가 부담해야 하는 고용승계의무는 종전 업체의 근로자별로 부담하는 것이 아니라 아래의 ‘특별한 사정’이 없는 한 종전 업체에서 종사하던 근로자 전체의 고용을 승계할 의무이기 때문이다. 따라서 고용승계기대권 인정 여부를 판단할 때에는 ‘해당 근로관계’뿐만 아니라 ‘해당 용역계약’을 둘러싼 여러 사정을 고려해야 하므로 용역업체의 변경에 따라 고용변동이 발생하는 해당 업체 자체를 기준으로 판단해야 한다.

다만, 고용승계기대권을 부인할 만한 ‘특별한 사정’([“]새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성되었다면, 특별한 사정이 없는 한 근로자에게는 그에 따라 새로운 용역업체로 고용이 승계

79) 정규직 전환 및 갱신기대권도 근로자 개인의 주관적 기대가 아니라 명시적 규정 및 ‘당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정’(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등)을 통해 인정되는 ‘객관적 기대’라는 측면에서 해당 근로자가 단기간 근로하였더라도 위와 같은 판단이 가능하다. 그러나 나머지 부분은 고용승계기대권과 맥락을 달리하므로 별도로 판단해야 한다.

되리라는 기대권이 인정된다.”)이 있는지 여부는 해당 근로자를 기준으로 판단해야 할 것으로 보인다(고용승계약정이 있는 경우를 포함).⁸⁰⁾ 이는 해당 근로자의 귀책사유 유무를 판단하는 것(승계 거부의 합리적 이유)이 아니라 객관적으로 보아 해당 근로자에게 고용승계기대권을 인정하기 어려운 사정이 있는지를 판단하는 것임을 유의해야 한다. 이와 유사한 사례로 대법원은⁸¹⁾ 고용승계기대권을 부인하면서도 “나아가 원심은, 참가인의 취업규칙은 만 60세에 도달하는 해당 월의 말일을 정년으로 정하고 있는데 참가인의 고용승계 거절 당시 원고는 만 66세였으므로 이는 참가인이 고용승계를 하지 않을 ‘특별한 사정’에 해당하는 것으로 볼 수 있으며, 이를 이유로 한 참가인의 원고에 대한 고용승계 거절을 연령을 이유로 한 부당한 차별로 보기 어렵다고 판단하였다.… 원심의 설시에 다소 부적절한 점이 있으나, 원고에게 고용승계에 관한 기대권이 인정되지 않는다는 결론은 정당하다.”라고 판시하였다. 원심의 설시 내용 중 다소 부적절한 점이 무엇인지 확인되지 않으나 고용승계기대권을 부인할 만한 ‘특별한 사정’은 개별 근로자를 기준으로 판단한 것으로 보인다. 이 사안에서 논자에 따라 66세인 근로자의 승계 거부를 ‘합리적 이유’로 볼 수도 있을 것이나 정년이 지난 고령자에 대한 갱신기대권 판단기준을 제시했던 판례와⁸²⁾ 같이 고용승계기대권 인정 여부와 관련된 것으로 보인다. 예컨대 취업규칙으로 근로할 수 있는 연령의 최대한도를 70세로 정한 경우 70세에 도달하는 근로자에게 계속 근로에 대한 객관적 기대가 형성되었다고 보기 어렵기 때문에 종전 용역업체 소속 근로자 전체에

80) 이러한 부분은 갱신기대권 및 정규직 전환기대권과 차이가 있다.

81) 대법원 2021. 6. 24. 선고 2017두72560 판결

82) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결(“정년을 이미 경과한 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는 앞서 본 제반 사정 외에 해당 직무의 성격에 의하여 요구되는 직무수행 능력과 당해 근로자의 업무수행 적격성, 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도, 해당 사업장에서 정년을 경과한 고령자가 근무하는 상태 및 계약이 갱신되어 온 사례 등을 종합적으로 고려하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지 여부를 판단하여야 한다.”)

게 고용승계기대권이 인정되더라도 70세에 도달한 개별 근로자에게는 기대권이 부인될 수 있다. 따라서 근로자별로 고용승계기대권 인정 여부를 달리 판단할 수 없으나 일단 고용승계기대권이 인정된다면 이차로 개별 근로자에게 특별한 사정이 있을 경우 해당 근로자에게 고용승계기대권이 부인될 수 있다. 그러나 근무기간이 짧은다는 사실은 고용승계기대권을 부인할 만한 특별한 사정이라고 보이지 않는다.

둘째, ‘도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행’의 존재만으로 새로운 용역업체에게 고용승계의무를 인정할 수 있는지 여부인데, 이에 대해 대법원 2020두45308 판결은 이를 인정하기 어렵다고 판단하는 것으로 보인다. 앞서 살펴본 논거 3가지 및 판결요지의 내용(‘새로운 용역업체와 근로자들의 인식’)에 비추어 보면 대법원은 새로운 용역업체가 용역업체가 바뀌더라도 종전 용역업체의 고용을 승계하는 관행이 있는 것을 알았거나 고용을 승계할 의무가 있다는 것을 알 수 있어야 한다고 판단하는 것으로 보인다. 새로운 용역업체가 자신이 어떠한 의무를 부담해야 하는지를 알 수 있어야 한다는 측면에서 보면 일응 수긍이 간다. 그러나 현실적으로 해당 분야에서 용역사업을 계속하였던 사용자라면 이러한 관행의 존재에 대해 충분히 알았거나 알 수 있었을 것이다.

3. 고용승계 거절의 합리적 이유

근로자에게 고용승계기대권이 인정되는 경우 ‘근로자가 고용승계를 원하였는데도 새로운 용역업체가 합리적 이유 없이 고용승계를 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 근로자에게 효력이 없다. 승계 거절의 합리적 이유에 대한 판단기준을 제시한 판결은 아직 없는데, 갱신 거절의 합리적 이유를 준용할 수도 있을 것이나 사용자의 변경이라는 측면에서 보면 사업양도 시 고용승계의무가 인정되는 경우의

승계 거부와 달리 판단할 이유가 없어 보인다. 즉 동일한 사용자를 대상으로 근로계약을 갱신하는 경우에서의 갱신 거절과 변경된 사용자에 의한 새로운 고용(승계)의 거부와는 차이가 있다.

판례는 사업양도 시 근로관계의 승계가 의무가 있다면, 사업양도 당사자 사이에 근로관계의 일부를 승계의 대상에서 제외하기로 하는 특약이 있는 경우 그러한 특약은 실질적으로 해고나 다름이 없으므로 근로기준법 제23조 제1항 소정의 정당한 이유가 있어야 유효하고, 영업양도 그 자체만을 사유로 삼아 근로자를 해고하는 것은 정당한 이유가 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다고 한다.⁸³⁾ 따라서 근로자의 고용승계기대권에 따른 새로운 사용자의 고용승계의무에도 위와 같이 적용된다고 보아야 한다. 근로기준법 제23조 제1항[“사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)을 하지 못한다.”]에 따라 사용자가 정당한 이유가 있다는 점을 주장·증명하여야 하므로⁸⁴⁾ 고용승계 거부의 합리적 이유도 새로운 사용자가 증명해야 한다. 그런데 해당 근로자와 기존에 근로관계를 형성 하였던 사용자가 아니라 새로운 사용자이므로 해당 근로자의 고용승계를 거부할 만한 합리적 이유를 찾기 어려울 뿐만 아니라 이를 입증 하기도 어려울 것으로 보인다. 따라서 채용요건 등을 구비하지 못했다는 등의 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 고용을 승계하는 것이 타당할 것이다.

여기서 고용승계기대권을 부인할 만한 ‘특별한 사정’과 고용승계 거부의 ‘합리적 이유’의 구분이 쉽지 않을 수 있으나 앞서 언급하였듯이 전자는 종전 용역업체 소속 근로자 전체에게 고용승계기대권이 인

83) 대법원 1994. 6. 28. 선고 93다33173 판결, 대법원 1991. 11. 12. 선고 91다12806 판결

84) 대법원 2015. 1. 29. 선고 2013다13146 판결, 대법원 2016. 11. 24. 선고 2015두 54759 판결 등. 갱신 거절도 해고와 마찬가지로 해고제한의 법리가 유추 적용되어 갱신 및 정규직 전환 거절에 합리적 이유가 있다는 사정도 사용자가 증명책임을 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결).

정되더라도 객관적으로 보아 특정 근로자에게 이를 인정하기 어려운 특별한 사정이 있는지에 대한 판단이다. 즉 ‘특별한 사정’은 “새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성”되었음에도 개별 근로자에게 계속 고용에 대한 객관적 기대 형성을 부인할 만한 사정을 말한다. 반면 고용승계 거부의 ‘합리적 이유’는 승계를 거부할 만한 개별 근로자의 귀책사유 등에 대한 판단이다. 예컨대 원사업주가 예산삭감 등을 이유로 종전 용역인원을 줄여 위탁할 경우 새로운 사용자가 줄어든 인원만큼 승계를 거부하면서 거부 기준을 종전 용역업체에서 징계전력이 있는 자 내지 일반건강진단 결과 ‘일방질병’ 판정을 받은 자 중 기존의 근로를 계속함으로써 병세가 악화될 우려가 있는 자로 한다고 정한 경우 이러한 기준은 승계 거부의 합리적 이유가 될 것이다.

한편 승계되는 근로관계의 범위와 관련하여 사업양도의 경우 법원은 “영업양도에 의하여 승계되는 근로관계는 계약체결일 현재 실제로 그 영업부문에서 근무하고 있는 근로자와의 근로관계만을 의미하고 계약체결일 이전에 해당 영업부문에서 근무하다가 해고된 근로자로서 해고의 효력을 다투는 근로자와의 근로관계까지 승계되는 것은 아니다.”라고 판시함으로써⁸⁵⁾ 해고의 효력을 다투는 근로자의 근로관계 승계를 원칙적으로 부정하고 있다. 다만 예외적으로 영업양도계약 체결 이전에 이미 해고무효 확인청구소송 등을 제기하여 승소확정 판결을 받았다면 근로자는 영업양도 당시 양도회사와 적법 유효한 근로관계에 있었다고 보아야 하므로 그 근로자와 양도회사와의 근로관계는 양수회사에게 승계된다고 보았다.⁸⁶⁾ 새로운 사용자가 부담해야 하는 승계사무의 대상자 범위에서 종전 사용자로부터 해고되어 해고의 효

85) 대법원 1995. 9. 29. 선고 94다54245 판결

86) 대법원 1994. 6. 28. 선고 93다33173 판결

력을 다두고 있는 근로자의 존재를 알 수 없다는 측면을 고려하면 위 판례의 태도에 일응 수긍이 갈 수도 있다. 그러나 근로자는 종전 사용자의 부당해고가 없었다면 고용이 승계되었을 것이고, 종전 사용자(양도인)는 전부 또는 일부 사업양도로 해당 사업을 더 이상 영위하지 않고 사업주체는 양수인으로 변경되었으므로 근로자는 부당해고로 확정되더라도 복귀할 사업장이 없어 일자리를 상실하는 불합리한 결과가 초래된다.⁸⁷⁾

반면 아웃소싱으로의 전환과 아웃소싱업체의 변경은 사업양도와 달리 원사업주와 종전 용역업체는 여전히 존속하므로 근로자의 해고가 새로운 사용자로 변경된 이후에 무효로 확정되더라도 종전 사용자의 근로자로서 지위는 그대로 유지하기 때문에 일자리 상실이라는 불합리한 결과는 발생하지 않을 수 있다. 그러나 종전 사용자의 부당해고가 없었다면 근로자는 계속 근로하던 작업장에서 고용승계되어 종전과 동일하게 근로하였을 것이고, 사용자가 용역계약이 만료되어 용역업체가 변경될 것을 알면서도 근로자를 괴롭힐 의도 내지 부당노동행위 의사를 가지고 해고하는 경우도 있을 수 있다. 따라서 새로운 사용자가 해당 근로자가 종전 사용자로부터 해고되어 해고의 효력을 다두고 있다는 사실을 알고 있었거나 충분히 알 수 있었다면 널리 고용승계의무를 인정해야 한다.⁸⁸⁾

87) 물론 사업의 일부가 양도되어 종전 사용자에게 잔존 사업이 있을 수 있으나 해당 근로자가 수행하던 업무는 양도되었으므로 잔존 사업에서 해당 근로자와의 근로관계를 계속 유지하는 것이 가능한지는 의구심이 있다.

88) 대법원 2007. 12. 27. 선고 2007다51017 판결은 사업양도에 관한 사안으로 해고의 효력을 다두고 있다는 사실이 아니라 ‘근로관계가 유효하게 존속하고 있는 사실을 알고 있었음이 분명’하여 고용승계를 인정한 사례이다. “나아가 비록 피고 법인의 설립 이후에야 비로소 원고와 개발원과의 사이에 적법·유효한 근로관계가 존재한다는 내용의 판결이 확정되었지만, 이 사건 재임용탈락을 부당해고로 인정한 구제명령, 재심판정, 제1, 2심의 행정소송에서 원고의 승소 등 소송의 진행경과를 볼 때, 피고 법인은 그 설립 당시에 이미 원고와 개발원 사이의 근로관계가 유효하게 존속하고 있는 사실을 알고 있었음이 분명한 이상, 원고와 개발원 사이의 근로관계 역시 피고 법인에게 그대로 승계되었다고 할 것이다.”

V. 나가는 글

이상에서 위탁·용역·도급 등의 아웃소싱사업을 둘러싼 노동법적 쟁점을 기간제 근로계약을 체결한 근로자를 중심으로 검토하였는데 이러한 법적 쟁점은 결국 이들의 근로관계 종료와 관련되어 있음을 쉽사리 알 수 있다. 용역 및 하청근로자인 이들은 간접고용이 갖는 문제점(사용자성의 문제와 고용불안)과 기간제근로의 문제점을 고스란히 안고 있는 것이다. 노동위원회 실무에서 해고와 관련된 노동분쟁 중 이들이 차지하는 비중이 상당히 높은 사실은 비단 어제오늘의 일이 아니고, 이 과정에서 다양한 실무상의 쟁점이 파생되는데 그중 몇 가지로 한정하여 살펴보았다.

정부는 지난 2017. 7. 20. ‘공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인’을 통해 그동안 정규직 전환 대상에 배제되었던 청소원·경비원·시설관리원 등의 용역근로를 정규직으로 전환함으로써 용역근로자의 고용안정을 도모하였다. 한편 정부는 2019. 9. 공공부문에 적용되는 ‘용역근로자 근로조건 보호지침’을 통해 용역계약 체결 시 고용승계조항(특별한 사정이 없는 한 고용을 승계) 및 고용유지조항(특별한 사정이 없는 한 용역계약기간 중 고용유지)을 계약서에 명시하도록 하였고, 법원은 이와 같은 고용승계약정에 근거로 고용승계기대권을 인정한 것이다. 입찰공고 시 위와 같은 고용승계 및 유지조항이 있는 용역계약 일반·특수조건 등을 첨부하여 공고하기 때문에 사용자가 입찰공고에 응했을 때 이미 자신이 고용승계 및 유지의무를 부담한다는 사실을 충분히 알고 있는 것이다. 이러한 사실에 비추어 보면 민간부문에서도 최소한 용역 및 도급계약 입찰 공고 시 고용승계를 조건으로 하는 것이 필요하다고 본다. 이로써 용역업체 등의 변경 시 고용을 승계하는 관행이 사회 전반에 형성되어 당연한 것으로 인식되길 기대해 본다.

주제어 : 위탁·용역·도급계약 등 아웃소싱계약, 기간제근로자, 시용기간, 사업의 완료에 필요한 기간, 고령자, 근로관계 자동종료 약정, 고용승계기대권

【참고문헌】

- 강선희, “용역업체 변경 시 고용승계기대권-대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결-”, 월간 「노동리뷰」 2021년 7월호(통권 제196호), 한국노동연구원, 2021.
- 강선희, “용역업체 등의 변경 시 관행 등을 근거로 한 고용승계기대권 및 두 가지 의문-대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결-”, 월간 「노동리뷰」 2021년 9월호(통권 제198호), 한국노동연구원, 2021.
- 강선희, “해고의 서면 통지 요건과 갱신 거절 등-대법원 2021. 10. 28 선고 2021두45114 판결-”, 월간 「노동리뷰」 2022년 1월호(통권 제202호), 한국노동연구원, 2022.
- 강선희, “채용형 인턴 및 정규직 전환자의 법적 지위와 차별행위로 인한 손해배상-대구지방법원 2022. 6. 16. 선고 2020가합212341 판결 -”, 월간 「노동리뷰」 2022년 8월호(통권 제209호), 한국노동연구원, 2022.
- 강희원, “용역계약의 해지가 근로관계의 자동소멸사유인가?”, 「노동법학」 제36호, 한국노동법학회, 2010.
- 권오성, “아파트 위탁관리계약의 해지와 근로관계의 종료”, 「노동판례백선」 제2판, 한국노동법학회, 박영사, 2021.
- 김형배, 「새로 쓴 노동법」 제25판, 박영사, 2016.
- 임종률, 「노동법」 제20판, 박영사, 2022.

[Abstract]

**Labor law Issues Regarding Service Contract etc.
Outsourcing Contract
- Focusing on Fixed-term Employee -**

*Kang, Sunbee**

This article reviewed various labor law issues related to fixed-term employees hired by outsourcing companies such as service providers.

First, the relationship between the consignment contract period etc. and fixed-term employment contracts was examined, focusing on probationary period and exceptions(when the period required for project completion, the elderly) to restrictions on the fixed-term employment period.

Second, this article reviewed the cancellation and termination of the consignment contract etc. and the termination of the employment relationship, focusing on two Supreme Court precedents(Supreme Court Decision 2007da62840, decided February 12, 2009 and Supreme Court Decision 2017da22315, decided October 31, 2017). In addition, the validity of each type of agreement to terminate the employment relationship was examined.

Finally, when switching to outsourcing or changing an outsourcing companies, this article examined the legal principles of succession of employment relations, focusing on two Supreme Court precedents(Supreme

* Lecturer, Korea Univ.

Court Decision 2016Doo57045, decided April 29, 2021 and Supreme Court Decision 2020Doo45308, decided June 3, 2021).

The above legal issues are eventually related to the termination of the employment contract of service workers. Service workers have the problems of indirect employment(whether the employer of the original company is an employer under the labor law, job insecurity) and problems of fixed-term work. It is hoped that it will be a variety of measures to promote employment stability for service workers.

Key words: Consignment Contract etc. Outsourcing Contract, Fixed-term Employee, Probationary Period, Period Required to Complete a Project, Elderly, Employment Relations Automatic Termination Agreement, Right to Expect Employment Succession